

Aunque no surge con claridad del texto constitucional, el trámite legislativo que sigue el proyecto es el de una ley ordinaria (aprobación por ambas Cámaras, con quórum y mayorías exigidas por la Constitución). Esta ley, pese a su aprobación bicameral, sigue siendo un proyecto, es decir, no adquiere todavía vigencia, porque será sometida al voto del pueblo. Sólo a partir del voto afirmativo del cuerpo electoral adquirirá la validez y eficacia propias de una ley.

c) Plebiscito

Es una votación realizada por el electorado de una nación, de una región o de una localidad sobre alguna cuestión específica. Se diferencia del *referéndum* en que el *plebiscito* es esencialmente consultivo, y el objeto de la aprobación de la consulta no consiste en la aprobación o desaprobación de una norma jurídica, sino que versa sobre un acto o una decisión de carácter político.

Asimismo, la doctrina francesa, basándose en los plebiscitos napoleónicos de 1799, 1802 y 1804, interpreta que el *plebiscito* es una especie de *referéndum* imperfecto, por cuanto no ofrece otra alternativa al cuerpo electoral más que aceptar o rechazar un acto elaborado previamente.

Los *plebiscitos* se refieren con frecuencia a cuestiones de índole territorial (agregación, segregación o fusión de territorios) (14). Este mismo caso se manifestó en nuestro país cuando se convocó por medio del decreto 2272/84 a un *plebiscito* para aprobar o rechazar el proyecto de tratado con Chile resolviendo la cuestión fronteriza del Canal de Beagle, el cual casi llegó en 1978 a provocar la guerra entre los dos países limítrofes. En la historia de nuestro país han existido varios *plebiscitos* que dieron una suerte de legitimidad a actos dictatoriales. Así, cabe mencionar el ya mencionado plebiscito de 1835, que ratificó la ley de la Legislatura porteña del 7 de marzo de dicho año, que investía al designado gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas con la suma del poder público.

Durante la época moderna, los plebiscitos se han realizado para conocer los deseos de los habitantes de un país o una zona al determinar su soberanía, convirtiéndose en un importante medio político de autodeterminación para algunos pueblos o naciones. En este sentido, el empleo del *plebiscito* se inició en tiempos de la Revolución Francesa, supuestamente como una alternativa a las anexiones por la fuerza y a las guerras de conquista. Los *plebis-*

mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año*.

(14) Los plebiscitos relativos a cuestiones territoriales, entre los que se puede mencionar Avignon, Niza, Bélgica, Saboya, etc. Sucedieron entre 1790 y 1793.

itos que se realizaron después de 1793 en zonas como Bélgica y Rumania estuvieron sin embargo acompañados por la intimidación a los votantes, para asegurar resultado coincidente con los deseos del Gobierno francés.

Igualmente, en 1852, Napoleón III organizó un *plebiscito* en Francia para aparentar que el golpe de Estado que acabó con la república y estableció el Segundo Imperio contaba con el apoyo popular.

Con el auge de los sentimientos nacionalistas en Europa, los *plebiscitos* empezaron a utilizarse como un instrumento democrático a partir de 1848. El papel del mismo fue de vital importancia en Italia luego de la Segunda Guerra Mundial (15), cuando el 2 de junio de 1946, se llama al pueblo a las urnas, donde fue proclamada la República en Italia, en abolición de la monarquía piemontesa vigente (según los términos que establece la Constitución aprobada el 1 de enero de 1948, queda prohibida la reorganización del Partido Fascista).

Durante el siglo XX, importantes *plebiscitos* provocaron la separación de Noruega (16) de la corona sueca en 1905 y la integración de la región del Sarre en Alemania en 1935 (17). Más recientemente, se utilizaron en las antiguas posesiones europeas en África para determinar las preferencias de los pueblos que acababan de obtener la independencia, como ocurrió en el antiguo Congo Belga.

8. FORMAS SEMIDIRECTAS IMPLÍCITAS O POSIBLES

Aunque estas instituciones no se hallan incorporadas de una manera explícita en el texto de nuestra Constitución Nacional, de todos modos tienen vigencia. En algunos casos se necesita de la sanción de una ley del Congreso,

(15) Casi 25 millones de votantes, aproximadamente el 89% de los italianos con derecho a voto, entre los que figuraban por primera vez las mujeres, ejercieron su derecho en el referéndum y en las elecciones celebradas respectivamente el 2 y 3 de junio de 1946. El resultado fue de un 54,3% de electores partidarios de la república. El 10 de junio, con la proclamación oficial del resultado, Italia se paso de un gobierno de facto a convertirse en una república.

(16) En el plebiscito de agosto de 1905 los noruegos votaron por una mayoría aplastante la separación de Suecia. El Parlamento sueco (*Riksdag*) ratificó la separación en octubre. Un mes más tarde, el príncipe Carlos de Dinamarca aceptó la corona noruega con el nombre de Haakon VII.

(17) Según el Tratado de Versalles (1919), las minas de carbón del Sarre pasaron a ser propiedad exclusiva de Francia durante un periodo de quince años, en compensación por la destrucción de las minas francesas durante la I Guerra Mundial. El tratado también disponía que se celebrara un plebiscito al final de ese periodo para determinar el futuro del territorio; en 1935 más de un 90% del electorado votó a favor de la incorporación a Alemania. El territorio sufrió intensos bombardeos durante la II Guerra Mundial y formó parte de la Zona de Ocupación Francesa en 1945. Ante las presiones francesas de incorporar el territorio a su soberanía a principios de la década de 1950, en 1956 la población del Sarre decidió, mediante un referéndum popular, la inmediata incorporación a Alemania. El 1 de enero de 1957, el Sarre, con el nombre oficial de *Saarland*, se convirtió en un estado de la República Federal de Alemania.

179

en otros un simple cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

a) *Recall*: Es el mecanismo por el cual se destituye a los funcionarios públicos, por decisión popular expresada mediante sufragio. Se puede instrumentar (mediante una ley) un procedimiento de recall para todos los funcionarios públicos, excepto para aquellos cuya forma de remoción o destitución esté expresamente prevista en la Constitución con un mecanismo que le sea propio. Como ejemplo se puede citar el caso de los jueces, sólo destituibles por juicio político en el Senado en el caso de los Magistrados de la Corte Suprema.

Resultaría importante la sanción de una ley que estableciera un procedimiento de recall para los funcionarios del Poder Ejecutivo.

b) *Acción Popular*: Consiste en aceptar la legitimación procesal activa en cabeza de cualquier ciudadano para cuestionar judicialmente la constitucionalidad o legitimidad de los actos de alguno de los poderes políticos del Estado (excluyendo el Poder Judicial), aunque no se vea afectado directamente un derecho subjetivo del actor. Se trata en este caso de la protección judicial de los intereses difusos.

c) *Veto Popular*: consistiría en la posibilidad de que el cuerpo electoral se pronuncie sobre una ley, luego de que ésta ha sido sancionada y promulgada. El funcionamiento popular tendría carácter retroactivo y funcionaría como condición resolutoria de la norma.

d) *Apelación popular por sentencia*: Es un procedimiento que consiste en someter a la decisión de un cuerpo electoral una sentencia judicial que declara la inconstitucionalidad de una ley, decreto, etc. (18). De acuerdo a lo que surge del art. 116 de nuestra Constitución Nacional no resulta aplicable en nuestro sistema.

9. LAS CONSULTAS POPULARES EN LA ARGENTINA

Las consultas populares son muy sensibles a la oportunidad de la convocatoria, a la propuesta del tema, a la interpretación que se le pretenda dar al resultado obtenido, a la rectitud del debate.

La primera *consulta popular* que se realizó fue la del acuerdo de Paz y Amistad con Chile, conocida popularmente como "la consulta del Beagle".

(18) Dicho método fue propuesto por Teodoro Roosevelt durante su campaña electoral en 1912 y poco tiempo después fue adoptado por la Constitución del Estado de Colorado, en donde se establece que el 5% de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral pueden solicitar que se someta a un *referéndum* una ley (o decreto) que haya sido declarada inconstitucional por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia estatal.

En la Provincia de Buenos Aires se realizó una *consulta popular* no vinculante para poder realizar una reforma a la Constitución Provincial, con el fin de incorporar la reelección del gobernador (por entonces el Dr. Duhalde). Pero la iniciativa partió del acuerdo de las cúpulas partidarias, donde se creyó que el llamado "voto cautivo" de los grandes partidos seguiría ciegamente la consigna de sus dirigentes; en realidad, el pueblo votó contra el contexto partidocrático de la reforma constitucional. Y el NO fue el triunfador en esa consulta aunque, como era no vinculante, pese a la negativa popular se procedió a realizar la reforma constitucional, paralelamente con la Constitución Nacional.

Tanto una como otra hubieran exigido una ley, ya que las *consultas populares* no estaban comprendidas en la Constitución Nacional ni en la norma infra constitucional. Las convocatorias a las elecciones de rutina las puede hacer por decreto el Poder Ejecutivo.

10. LA REGULACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA, LUEGO DE LA REFORMA DE 1994

Las cláusulas del art. 40 de La Constitución Nacional fueron sancionadas por la Convención Constituyente de 1994 en virtud de la habilitación conferida por el art. 3º inc. c) de la ley 24.309, que declara la necesidad de la Reforma.

En el segundo párrafo del nuevo art. 40, se hace referencia a la que denomina "*consulta popular no vinculante*", la cual puede ser convocada por el Congreso o por el Poder Ejecutivo Nacional "dentro de sus respectivas competencias". Este párrafo es tomado por la doctrina tradicional en el sentido de que la consulta no vinculante será dispuesta por el órgano al cual le corresponda tomar la decisión sobre determinado acto; así, las atribuciones le corresponden al Congreso de la Nación o al Poder Ejecutivo Nacional.

Si bien la Constitución Nacional la denomina *consulta popular no vinculante*, en realidad se trata de un *plebiscito*. Cuando la norma se refiere al carácter de no vinculante que adquiere dicha institución, hace referencia a que su resultado no obliga al órgano que lo convocó a tomar una decisión acorde con el pronunciamiento del pueblo, aunque políticamente y moralmente sería más que reprochable no hacerlo de esa manera. Por otro lado, la credibilidad que tendría el gobierno frente a este caso quedaría seriamente resentida.

En el segundo párrafo del art. 40 se establece que en los casos de consulta popular no vinculante, el voto no será obligatorio.

No resultaba necesaria la incorporación al texto constitucional de la consulta popular no vinculante como tampoco del plebiscito, ya que los mismos se encontraban implícitos en el art. 33, que incorpora todos los derechos no enumerados explícitamente que surjan del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno; éste es precisamente el caso de estos métodos de consulta popular.

El tercer y último párrafo establecen la obligación del Congreso de la Nación de reglamentar (a través de una ley que sea sancionada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara) las materias, los procedimientos y oportunidad de la consulta popular.

11. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA ARGENTINA

a) Fallo de la Corte Suprema de Justicia: "*Baeza, Aníbal R. c. Gobierno Nacional s/ amparo*", del 28 de agosto de 1984 (19).

a.1) Derecho

Fundan el derecho en los arts. 1º, 19, 22, 67 inc. 14 y 19, 94, 100 y 101 de la Constitución Nacional (numeración anterior a 1994), decreto 2272/84, art. 2º de la ley 27, art. 16, 2ª parte de la ley 48, art. 322 del Código Procesal de la Nación, art. 21 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

a.2) Antecedentes legislativos

El fin y las consecuencias del "control" que el Poder Judicial ejerce sobre las actividades ejecutivas y legislativas, requieren la existencia de un caso o una controversia judicial, que sea observado rigurosamente para preservar el principio de división de poderes. Este último principio es un presupuesto básico del control de constitucionalidad instituido por el Congreso de la Confederación Argentina, en ocasión de ser sancionada la ley 132, que fuera la primera ley de Organización Judicial Nacional.

El punto fue luego recogido por la ley 27 sancionada por el Congreso de la Nación Argentina en octubre de 1862, encontrándose actualmente vigente la parte pertinente de dicha ley.

a.3) Precedentes jurisprudenciales

Fallos: 12:372; 95:51; 115:163; 242:353 considerando 3º; 256:104 considerando 2º; 32:12 y 127; 33:152, considerandos 17 y 24, p. 189 y p. 193; 242:353; 238:288; 270:85; "*Hidronor S.A. c. Provincia del Neuquén*" (CS, 28/2/1973, LA LEY, 154-517/523); 235:171 y 512; 248:577; 258:220; 261:208; 301:107, 219, 248; 302:207; 114:823; 119:474; LA LEY, 83-671; Rep. LA LEY, XLI-2755, sum. 480; XLI-2882, sum. 1562; LA LEY, 1980-A, 642; LA LEY, 1980-D, 207; 112:63; 118:278; 150:89; 181:264; 257:127; 261:409; 264:416; 113:613; Rep. LA LEY, XXVI-1346, sum. 111; LA LEY, 124-625, LA LEY, 1980-D, 506.

(19) "*Baeza, Aníbal R. c. Gobierno Nacional s/ amparo*", LA LEY, 1984-D, 107 a 113; Fallos: 306:1125.

a.4) Jurisprudencia comparada

Norteamericana (341 U.S. 149); (341 U.S. 123, ps. 149 y siguientes); (312 U.S. 270, p. 273).

a.5) Objeto

El Dr. Aníbal R. Baeza promovió acción de amparo contra el Gobierno Nacional con el fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad del decreto 2272/84 en el que se convocó a una consulta popular no vinculante. El actor sostiene que fue designado con el cargo de Presidente para integrar una mesa en las elecciones del 30 de octubre de 1983, y acciona ante el temor de ser designado nuevamente para el mismo cargo, al cual se vería obligado a concurrir, en virtud de normas que él considera inconstitucionales.

a.6) Elementos fácticos

El Poder Ejecutivo Nacional dicta el decreto 2272/84 por el cual se convocaba a la ciudadanía a una consulta popular que resultaría ser no vinculante, por la que se iba a tratar una solución sobre el conflictivo tema de límites con Chile, en la zona del Canal de Beagle. El actor solicita al tribunal de la causa se encargue de oficiarle al Ministro del Interior que debía abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que lleven a la realización de la consulta popular.

a.7) Primera y segunda instancia

En primera instancia el juez analiza previamente la procedencia, donde admite que el actor tiene un interés legítimo para actuar en el proceso, pero el decreto que se ataca no resulta violatorio del art. 22 de la Constitución Nacional, no invade atribuciones de los otros dos poderes del Gobierno, ni tampoco altera el espíritu de la Constitución Nacional. Se desestimó el planteo "in limine". Por esta decisión el actor interpuso recurso de apelación ante la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, la que confirmó la decisión de primera instancia, fundándose en la falta de legitimación de la parte actora para la presentación del amparo.

Frente a esta decisión interpone un recurso extraordinario federal, el que fue rechazado.

a.8) Resolución de la Corte Suprema

Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario fue rechazado, la parte actora ocurre en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, facultad que le es conferida por intermedio de los artículos 94 (20), 100 (21),

(20) Constitución de la Nación Argentina de 1853. Art. 94: El Poder judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.

(21) Constitución de la Nación Argentina de 1853. Art. 100: Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que

101 (22); por este último se determina la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los asuntos en que la Nación sea parte. Lo mismo es ejercitado en los casos que su carácter resulte ser materia contenciosa (art. 2º, ley 27) (23).

La Corte considera qué tipo de causas podrá solicitar la intervención de la justicia: en aquellos casos cuyo fin perseguido consista en la determinación del derecho que se debate entre las partes opuestas en dicha causa. Pero en esta causa no se dan estos presupuestos; por este motivo, cuando se intenta obtener una declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no le otorga dicha intervención.

Siguiendo con la doctrina imperante en la Corte Suprema de la Nación, esta siempre negó que el Poder Judicial tuviese la facultad de expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de las normas emitidas por los otros dos Poderes.

El Tribunal Supremo analiza la legitimación de la parte para iniciar el reclamo y considera que, si bien no solicita la tutela específica del derecho que invoca, de todos modos no media un interés concreto para iniciar el reclamo.

Siguiendo a la jurisprudencia norteamericana, nuestra Corte considera que es necesaria actividad administrativa a través de la redacción de un acto administrativo; además, este acto debe afectar en forma directa al sujeto que realiza la petición, para que el mismo se llegue a concretar. Pero en este caso, el actor solicita, o bien que se lo exima de esa designación, o de lo contrario, en el caso de ser designado e hipotéticamente él se negase a concurrir o presentara una excusa para no hacerlo, se lo protegiese de eventuales sanciones. En este caso no estaría presente la actividad que es un requisito esencial para la existencia del acto, por lo tanto no existiría un interés concreto del sujeto.

Por lo tanto, la Corte sostiene que no es un caso de los que contemplan los arts. 100 y 101 de la Constitución de la Nación Argentina de 1853 y el art. 2º de la ley 27, los cuales son los únicos supuestos en los que cabe que el ejerci-

versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 11 del artículo 67, y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias, y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.

(22) Constitución de la Nación Argentina de 1853. Art. 101: En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros, y cónsules extranjeros, y en los que alguna Provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.

(23) Art. 2º de la ley 27: Nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte.

cio del Poder Judicial sea atribuido por aquellas normas constitucionales y las leyes reglamentarias del Congreso a la Corte Suprema y a los Tribunales inferiores de la Nación.

Se desestima la queja (Dres. Genaro Carrió, José Caballero, Enrique Petracchi).

a.9) Voto en disidencia del Dr. Carlos Fayt

Si bien mantiene la postura de la mayoría en cuanto a que es una conjetura hipotética del actor y no se basa en acto administrativo alguno, por otro lado no está de acuerdo en que su demanda estaría dirigida a la protección jurisdiccional del sistema representativo, mediante un instituto de la democracia indirecta.

Menciona además que dicha consulta no iba a tener un carácter obligatorio de concurrencia por parte de la ciudadanía, pero iba tener un alcance no vinculante para el Poder Legislativo, y produciría sus efectos sobre el cuerpo electoral del cual formaría parte el actor.

Pasa a analizar si la acción declarativa resulta procedente o no. Para ello se funda en el fallo "Hidronor S.A. c. Provincia del Neuquén", donde se sostiene la inexistencia de obstáculos de índole constitucional para su admisión, de acuerdo a lo normado en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial.

El referéndum va a ser el instrumento por el cual el ciudadano va a poder tomar partido directamente de las decisiones del gobierno, haciéndole una vinculación estrecha con las formas de democracia semidirecta.

En el caso en cuestión, se trata de una consulta no vinculante al cuerpo electoral y no de un referéndum. La consulta popular no consiste en un acto por el cual el pueblo va a emitir su opinión para luego transformarla en su voluntad en el momento de sancionar una ley. Por eso, no se encontraría alterado el contenido formal y material del art. 22 de la Constitución Nacional.

Por ello, se desestima la queja.

a.10) Voto en disidencia del Dr. Augusto Belluscio

Comienza con un relato del proceso, donde en primera instancia el juez admite que el actor tiene un interés que lo legitima para actuar, pero el decreto que se ataca no resulta violatorio del art. 22 de la Constitución Nacional. Continúa dándole mayor relevancia a la presentación del recurso extraordinario federal, que se basó en que la sentencia resultaba arbitraria por decidir una cuestión no planteada, la legitimación activa en la causa, y revisando una materia que no había sido objeto del recurso de apelación, e insistió en la cuestión constitucional propuesta. El a quo expidió una providencia de la cual destaca que contiene las consideraciones del caso, pero no la parte dispositiva expresa. Contra esta resolución el actor plantea la queja, por la que solicitaba un recurso extraordinario federal, que fue rechazado.

Sostiene que como en primera instancia le había sido reconocida al actor la legitimación activa, en segunda instancia éste no necesitó reclamarla.

El decreto 2272/84 no se encontraría opuesto al art. 22 de la Constitución Nacional, por confirmar como forma de gobierno utilizada la representativa. Además, no se contempla la actuación directa del pueblo en los actos de gobierno (art. 1º de la Constitución Nacional). Recalca el carácter de voluntaria que tendría la emisión del voto por parte de los ciudadanos y el de voto no vinculante, lo que le da un estado de ser una consulta de opiniones que, sea el resultado favorable o no al tratado con Chile, no implica que el cuerpo electoral ejecute un acto de gobierno.

Nuestra Constitución no autorizaba (ni prohibía) la realización de consultas populares; por ello el Poder Ejecutivo tendría la posibilidad de recurrir a este mecanismo de consulta popular para conocer la opinión de los ciudadanos sobre un tema tan delicado que hace a la soberanía del país.

Concluye diciendo que el acto no está en pugna con disposiciones constitucionales al Poder Judicial, por lo que le estaría vedado a éste abrir un juicio sobre su oportunidad o conveniencia, el cual pertenece a la discreción de la autoridad que lo otorgó y escapa a los poderes del Tribunal.

Se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario, se deja sin efecto la sentencia apelada y se confirma la de primera instancia en cuanto al rechazo el recurso de amparo interpuesto por el actor.

a.11) Comentario al fallo

Para comenzar con el análisis del fallo, debe primero realizarse una ubicación en tiempo y espacio de la Corte de 1984. El 10 de diciembre de 1983, con el advenimiento de la democracia, se efectuó un recambio completo en la composición de la Corte Suprema de Justicia, reemplazando a sus 5 ministros nombrados por el gobierno de facto, mediante los mecanismos establecidos por la Constitución de 1853. Esta nueva Corte consistía en una mayoría de tres miembros allegados al nuevo gobierno radical, los Dres. Genaro Carrió, José Severo Caballero y César Augusto Belluscio, y de dos provenientes de otros sectores, Dres. Enrique Petracchi y Carlos Fayt.

En el caso analizado se debate el decreto 2272/84, por el que se llamó a una consulta popular no vinculante a la ciudadanía para debatir el tratado con Chile, el que pondría fin al conflicto limítrofe en la zona austral, luego de la mediación papal (24) solicitada en 1979 por ambas partes.

El actor había sido designado para presidir una mesa durante el primer comicio electoral de la etapa de transición por la que atravesaba nuestro país luego del gobierno de facto, en el cual el llamamiento a elecciones vino por

parte de la dictadura militar. En el entusiasmo provocado por este primer comicio electoral, el desorden imperante generaba incertidumbre acerca de si, concretamente, alguna vez iba a realizarse otra elección o no. En el momento en que se hace el anuncio de una consulta popular, el actor estimó que podría ser convocado nuevamente, pero no disponía de indicios de que esto fuera a suceder. Así es como el actor se encuentra frente a la "falta de certeza".

Concordamos con el Dr. Belluscio en el análisis hecho sobre la legitimación activa para actuar por la parte actora, ya que en primera instancia (aunque esta resolución fue declarada nula a posteriori) habría obtenido este estado, con lo cual resultaría nocivo para el proceso y el fin que se intentaba perseguir.

Es importante hacer una distinción entre el "carácter voluntario" y "no vinculante". El primero es la obligación o no para la ciudadanía que tendría la emisión del voto, mientras que el "voto no vinculante" se refiere a que el Poder Legislativo podrá legislar con toda libertad, sin limitarse a confirmar el voto mayoritario de la ciudadanía. Por esta razón, como de esta manera el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, no se encontraría alterado el contenido formal y material del art. 22 de la Constitución Nacional.

b) Fallo de la Cámara Nacional Electoral, en los autos: "*Fonrouge, Alberto s/ amparo*", 28 de agosto de 1984 (25)

b.1) Derecho

Fundan el derecho en los arts. 8º, 19, 22, 33, 67, 86, 100, 101 y 104 de la Constitución Nacional, decreto 2272/84, leyes 16.652, 16.986, 19.688 y 22.627.

b.2) Jurisprudencia

Fallos: 291:591 y 292:12; "Baeza, Aníbal R. c. Gobierno Nacional s/ amparo".

b.3) Objeto

El abogado interviniente en autos promovió acción de amparo con el fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad del decreto 2272/84, por el que se convocó a una consulta popular no vinculante, sosteniendo que la consulta popular no vinculante afecta la legítima representación. Solicita además como medida preliminar de no innovar, la suspensión del acto electoral.

b.4) Elementos fácticos

Como ya se dijo, el Poder Ejecutivo Nacional emite el decreto 2272/84 por el cual se convocaba a la ciudadanía a una consulta popular que resultaría ser

(24) Tratado de Paz y Amistad. Ciudad de Vaticano, 1985.

(25) "Fonrouge, Alberto s/ amparo", LA LEY, 1984-D. 122 a 131.

183

no vinculante, por la que se iba a tratar una solución sobre el conflictivo tema de límites con Chile, en la zona del Canal de Beagle.

El patrocinante actúa por la vía de amparo, al considerar que existiría la inminencia de un hecho lesivo derivado de la puesta en marcha por el Ministerio del Interior de los actos preparativos de los comicios, e intenta evitar el menoscabo de las atribuciones otorgadas a los diputados como sus representantes en virtud de su elección en comicios del año anterior.

b.5) Fallo de primera instancia

En el Juzgado Federal Electoral de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, se presentó la demanda.

Si bien la acción de amparo que se interpuso no se encontraría encuadrada jurídicamente dentro de las causales dispuestas por la ley 16.986, la misma también resultaría viable, por cuanto se hace un llamado al pueblo para la realización de una consulta popular aunque este instituto no se encontraría inserto en nuestra Constitución Nacional (arts. 1º y 22).

Dicho juzgado declara admisible la acción de amparo y dispone una medida precautoria de no innovar suspendiendo el acto electoral. Se solicita como prueba informativa, el informe emitido por el Ministerio del Interior, estableciendo que se le debe hacer saber al Poder Ejecutivo Nacional que hasta que no exista una resolución definitiva del caso en cuestión, éste deberá abstenerse de realizar el comicio.

b.6) Dictamen del Fiscal Federal de Río Gallegos

Cuestiona la legitimación activa y considera impertinente la declaración del juez referida a que la consulta popular a la que se convoca por el decreto en cuestión no se encontraría contemplada en la Constitución Nacional.

El accionante no tiene legitimación activa ni como abogado ni como ciudadano, desde el momento en que no tiene derecho subjetivo o interés legítimo afectados.

Solicita se rechace la acción de amparo por resultar improcedente, correspondiendo además dejar sin efecto la medida cautelar al considerarla arbitraria.

b.7) Dictamen del Procurador Fiscal Federal

Interpone el recurso de apelación contra esta última resolución, negando así también la personería al accionante por falta de legitimación activa, debido a que no acompaña poder que acredite tal estado; para agregar que las garantías constitucionales les fueron otorgadas a los particulares y sólo podrán ser invocadas por sus titulares.

La consulta no es vinculante sino solamente voluntaria.

La declaración de inconstitucionalidad se encuentra prohibida en el art. 2º inc. d) de la ley 16.986 (26).

Sostiene que la acción es improcedente y con respecto a la medida cautelar, ésta queda sin sustento.

b.8) Resolución de la Cámara Nacional Electoral

El decreto 2272/81 convoca a los ciudadanos a que voluntariamente expresen su opinión en la consulta popular que se realizará para poner fin al conflicto limítrofe con Chile. La respuesta de la ciudadanía será afirmativa o negativa.

El poder de participación del pueblo es un elemento que caracteriza a la democracia, el cual deberá ser ejercido si se tratan cuestiones que puedan afectar a futuras generaciones.

La soberanía del pueblo y la forma republicana y representativa de gobierno son principios congruentes, que van unidos uno con el otro en los arts. 22 y 33 de la Constitución Nacional. El ciudadano tiene la posibilidad de concurrir a expresarse para poder brindar su opinión en el momento en que es consultado.

Los poderes que se delegan por las provincias al Gobierno Federal (art. 104) (27), en los arts. 67, 86 y 100, constituyen un "complejo" armónico de competencias que puede ejercer el Poder Ejecutivo (art. 86). Integrado en todo su articulado, debe ser interpretado tendiente a la unión nacional, la justicia, la paz, la defensa común y la solidaridad, todos principios vigentes en el Preámbulo.

Debido a que esta consulta será de tipo voluntario, todo ciudadano permanece garantizado del art. 19, de manera que no se encontrará afectado ningún derecho subjetivo ni constitucional. Asimismo, el Poder Legislativo va a mantener una plena autonomía para debatir, aprobar o rechazar el tratado en cuestión, así como el Poder Judicial para decidir sobre todas aquellas causas que versen sobre puntos regidos en la Constitución y por las leyes.

Los presentantes accionan en su carácter de ciudadanos que concurrieron a las urnas el 30 de octubre de 1983, y con el fin de evitar que sus representantes en el Congreso de la Nación sufran el menoscabo del decreto 2272/84 citado.

(26) Art. 2º inc. d) de la ley 16.986. "La determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas".

(27) Art. 104 de la Constitución Nacional de 1853: Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

En este tipo de casos la acción de amparo no es admisible, debido a que la determinación de la invalidez del acto requiere la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos y ordenanzas.

La Cámara Nacional Electoral resuelve revocar la resolución de primera instancia y denegar la acción de amparo, integralmente y a todos sus efectos. (Dres. Héctor R. Orlandi, Enrique Rocca —según su voto—, Rodolfo Munne.)

b.9) Comentario

No coincidimos con el trato dado a la cuestión en primera instancia, donde no fue tratado con el debido análisis de los requisitos indispensables; por tal motivo, no debió prosperar la acción.

La falta de acreditación de la personería que se pretende invocar demostraría el desinterés del actor, ya que pudo haber subsanado esta omisión y no lo hizo. El Código Procesal le otorga la posibilidad de presentarse como un simple mandatario en casos de que exista un peligro en la demora, debiendo para ello acreditar la personería de un modo fehaciente dentro del plazo prudencial de 40 días hábiles desde que inició la acción. Si no lo hace, es nulo todo lo actuado por el gestor, y se procede luego al archivo y paralización de las actuaciones.

El juez reconoce que la presentación no se encontraría dentro de lo previsto por la Ley 16.986 de Amparo, pero de todos modos considera que es viable porque la consulta popular no estaría taxativamente incorporada a la Constitución Nacional. Pero no se detiene a ver la importancia que tiene un amparo como garantía constitucional, que va a ser la que va a velar por los derechos reconocidos en la Constitución (con la reforma de 1994 va a ser incorporada taxativamente a la norma Constitucional).

En lo que hace a la delegación de poderes que se encuentran en los arts. 104, 67, 86 y 100, se deben analizar de una manera armónica todos ellos, teniendo siempre como único fin la unión nacional de todos los argentinos, sin olvidar el Preámbulo, donde se encuentra el fin de nuestra Norma Fundamental.

12. LEGISLACIÓN ARGENTINA

La ley 25.432 que regula la consulta popular fue sancionada el 23 de mayo de 2001 y promulgada el 21 de junio, y su publicación en el Boletín Oficial es del 27 de junio de ese año.

La ley dispone dos institutos a los que llama "*Consulta Popular Vinculante*" y "*Consulta Popular no Vinculante*".

La "*Consulta Popular Vinculante*" indica que la iniciativa para este tipo de proyectos la tendrá la Cámara de Diputados por ser ésta la representante del pueblo, para lo cual podrá someterse todo proyecto de ley con excepción de

aquellos cuyos procedimientos se encuentren regidos en la Constitución Nacional, mediante la determinación de la Cámara de origen, o que se exija una mayoría determinada para su aprobación.

La ley por la que se convoque a los ciudadanos a una *Consulta Popular Vinculante* se deberá tratar en una sesión especial. Exige para su sanción obtener una mayoría absoluta de votos de los miembros presentes en cada una de las Cámaras.

El voto de los ciudadanos va a ser obligatorio, y el Poder Legislativo va a tener que acatar al voto de la mayoría. Este nuevo instrumento fue incorporado en nuestra Constitución y funciona como un referéndum.

Se establece que todo proyecto que se someta a *Consulta Popular Vinculante* será validado cuando al menos el 35% de los ciudadanos que se encuentren inscriptos en el padrón electoral hayan sufragado. Es lógico que se establezca un mínimo, debido al carácter vinculante que tiene la consulta, ya que el resultado de este comicio dará a todos los ciudadanos una norma que los va a regir a ellos y a futuras generaciones. Este es el motivo por el que deberá ser tratado con mucha responsabilidad en el momento de decidir.

De esta manera, cuando un proyecto sea sometido a *Consulta Popular Vinculante*, si obtiene la mayoría de los votos válidos afirmativos se convierte automáticamente en ley, la que será publicada en el Boletín Oficial dentro de los 10 días hábiles posteriores a su promulgación.

Pero en caso de resultado adverso en los comicios, no podrá ser reiterado sino después de un período que se establece en 2 años a contar desde la realización de la consulta, como así también no se podrá realizar la misma consulta durante el mismo período.

"*Consulta Popular no Vinculante*" es un mecanismo que podrá tratar todo asunto que tenga un interés general para la Nación, a excepción de aquellos proyectos de ley que por su procedimiento se encuentren especialmente reglados en la Constitución Nacional. El voto de la ciudadanía será voluntario, a diferencia de la "*Consulta Popular Vinculante*", donde es obligatorio.

La convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo Nacional deberá efectuarse mediante decreto decidido en Acuerdo General de Ministros y refrendado por todos ellos.

Asimismo, en el Poder Legislativo la convocatoria la podrá solicitar cualquiera de las dos Cámaras, la que deberá tener para su aprobación el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes en cada una de ellas.

Cuando el proyecto haya sido sometido a consulta popular no vinculante y como resultado obtenga el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, deberá ser tratado por el Congreso de la Nación, quedando automáticamente incorporado al plan de labor parlamentaria de la Cámara de Diputados de la sesión siguiente a la fecha en que fue proclamado el resultado del comicio por la autoridad electoral.

185

Asimismo, la ley dispone para ambos institutos que la ley o decreto de convocatoria a una consulta popular deberá contener el texto íntegro del proyecto de ley o decisión política que va a ser objeto de la consulta y señalar las preguntas a contestar claramente, las que no admitirán como respuesta otra cosa que respuestas afirmativas o negativas (SI o NO).

Dicha Consulta Popular podrá ser convocada por una ley que dicte el Congreso de la Nación o por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que deberán ser publicados no sólo en el Boletín Oficial, como es habitual en todo tipo de normas, sino que, como en este caso se intenta llegar a toda la ciudadanía, se publicará también en el diario de mayor circulación en cada una de las provincias y en el diario de mayor circulación en todo el territorio nacional. Deberá ser difundida por todo tipo de medios radiales, televisivos y gráficos en una forma clara y precisa.

Se habilita a los partidos políticos que tengan interés a exponer sus posturas por uno u otro caso, a través de campañas que podrán realizar en los espacios gratuitos que se asignarán en los medios de comunicación.

Esta consulta deberá realizarse dentro de un plazo que se fijará en los 60 días como mínimo y no deberá superar los 120 días, corridos desde la fecha de publicación de la ley o decreto de convocatoria en el Boletín Oficial.

Con referencia a los votos en blanco, éstos no serán computados, debido a que lo que se busca es la opinión de la población, y al encontrarse en blanco no resultan significativos.

Asimismo fija algo que considero novedoso y sano: el hecho de que la consulta popular no pueda coincidir con ningún otro acto electoral, para que las ideas políticas no puedan llegar a confundir a la ciudadanía en ocasión de la consulta popular, y den una opinión distinta a la que darían en otra situación.

Este tipo de consultas será regido por el Código Nacional Electoral, siempre que no se opongan a la Ley de Consulta Popular. La competencia en lo que hace a los comicios la tendrá la Justicia Nacional Electoral.

13. CONCLUSIONES

Hace algunos años, la provincia argentina de Córdoba experimentó la realización de una consulta popular en donde se consultaba al pueblo sobre la necesidad de realizar una reforma en su Constitución para establecer un sistema unicameral de sólo 70 legisladores, en reemplazo de los 133 de ambas Cámaras. La consulta obtuvo el voto afirmativo, y la Cámara de Diputados sancionó la ley que declaró la necesidad de reformar la Constitución provincial.

Del mismo modo este mecanismo ha sido invocado reiteradamente en varias provincias en los últimos años, aunque pocas veces se ha llegado a la

realización del comicio. Si bien el espíritu y la letra de la Constitución reformada en 1994 apuntan claramente a la prevención del uso de este mecanismo por circunstancias coyunturales (la precaución de no permitir la votación simultánea con las elecciones a cargos públicos que fija la ley reglamentaria es un claro indicio de ello), el caso cordobés y algunos otros intentos más muestran que muchas veces el interés político es el predominante a la hora de decidir la apelación al pueblo.

En 1984 se dio el más importante y decisivo antecedente de consulta popular que registra nuestro país. Allí, un tratado de límites fue sometido a la opinión popular. No se hizo menoscabo en ningún momento de las atribuciones del Congreso, que siempre conservó su facultad de rechazar el acuerdo, pero el peso del resultado electoral inclinó la balanza hacia la aprobación del Tratado. Debe recordarse que la votación final del Senado fue de un estrechísimo 23 a 22 (1 abstención) a favor del acuerdo.

Esta decisiva consulta popular fue convocada 10 años antes de la reforma constitucional que incorporó el mecanismo de manera explícita en la Carta Magna. Como se ve reiteradamente en este capítulo, el consenso de muchos constitucionalistas ya era que este tipo de consulta no vinculante se hallaba implícito en la Constitución de 1853, lo que confirmó el Poder Judicial a través de los dos fallos aquí analizados ("Baeza" y "Fonrouge"). Entonces cabe preguntarse: *¿era necesaria la incorporación explícita de la consulta popular en el texto constitucional? ¿Qué es lo que falta, luego de la reforma, para que se convierta en un instrumento de uso común en la vida del país?*

Respecto a la primera pregunta, la definición de la consulta popular, especialmente la de aquella de carácter vinculante, probablemente fuese necesaria, ya que daría lugar a su reglamentación y acabaría con las ambigüedades que siempre supone la interpretación de lo que está implícito en la Constitución. Si se logró el objetivo, es materia de discusión. La ley 25.432 es muy clara en todo lo que hace a los recaudos formales de la consulta popular, pero no tanto en lo que hace a los *motivos* de la convocatoria. La ley habla de "todo asunto de interés general de la Nación" en la consulta no vinculante, y de "todo proyecto de ley" en la versión vinculante del mecanismo. Posiblemente, en un país de larga trayectoria en lo que a formas plebiscitarias se refiere, como Suiza, no habría dudas respecto a qué asuntos son "de interés nacional" o qué "proyectos de ley" pueden consultarse al pueblo; pero en Argentina, país con escasa tradición en este aspecto, esos términos son demasiado vagos. Una pregunta formulada de manera suspicaz podría incluso saltar la barrera que impide emplear este mecanismo en "proyectos de ley cuya sanción esté especialmente reglada por la Constitución". La ley debería haber mencionado de manera específica qué materias serían sometidas a consulta popular, con menos requisitos formales.

Estas reflexiones llevan a una posible respuesta a la segunda pregunta (¿qué falta...?). Falta tradición, que muchas veces va más allá de la jurispru-

186

dencia o la interpretación de la ley y que se inserta en el plano cultural. En el fallo "Fonrouge" vemos una serie de idas y venidas judiciales en las sucesivas instancias, síntoma de dudas que bien podrían repetirse en alguna consulta popular futura, pese a la nueva Constitución. Pero sobre todo falta establecer finalmente el lugar que las formas de democracia directa o semidirecta tendrán en nuestro país, donde hasta ahora la democracia indirecta ha sido la norma casi absoluta.

Finalmente, no podemos dejar pasar por alto que tanto en la Constitución Argentina como en sus normas reglamentarias, el único poder no habilitado a efectuar consultas es el Poder Judicial. Ello se debe a que éste tiene la competencia excluyente y exclusiva en materia de dictado de sentencias y también de control de constitucionalidad, por eso sus decisiones no pueden ser sometidas a consulta popular.

En una república democrática todos los poderes deben estar sometidos a una consulta popular, aún el Poder Judicial, pero con los siguientes requisitos: voluntariedad, facultatividad y gravedad institucional.

La *voluntariedad* está dada en que el único órgano habilitado para desarrollarla sería el mismo Poder Judicial, porque de otro modo se estaría poniendo en peligro la intervención de los otros poderes en la decisión de causas con estricto tratamiento jurisdiccional. En referencia a lo *facultativo*, por sus características especiales tendría carácter de no vinculante y podría ser utilizado para darle fuerza a una decisión judicial significativa o para conocer la opinión de la ciudadanía. Con relación a la *gravedad institucional* significa que la resolución de la causa tendría que afectar alguna cuestión más allá del mero interés de las partes y enfocarse hacia uno general.

A modo de cierre de este capítulo, es importante destacar que el mecanismo de la consulta popular en algunos casos permite, según nuestra opinión, revestir el carácter de un llamado de atención a las autoridades instituidas, a la vez que un rechazo a las posturas de las cúpulas partidarias y darle más valor a la soberanía popular, el único poder supremo en una nación.

Al margen de estos comentarios positivos, debemos alertar que existen algunos peligros con la aplicación de este instituto, y nos referimos a los medios masivos de comunicación corporativa y globalizada que pueden inducir a la opinión pública a la toma de decisiones erróneas o incorrectas, contrarias al interés general de la ciudadanía.

La inducción negativa de la que hablamos, tendría su origen en por ejemplo una información filtrada o incompleta, que haría caer a los sufragantes en decisiones atentatorias al bienestar general, impidiendo así una opinión libre e independiente. Creemos necesario que por parte del Estado, se ejerza un estricto control indelegable, de la información suministrada al electorado, única posibilidad de que una consulta popular cumpla con los fines previstos en la Constitución Nacional y su ley reglamentaria. Todo ello en salvaguarda de los intereses de la democracia, evitándose así

la manipulación de los políticos de turno o conglomerados de poder político y económico.

~ Este es el único camino para robustecer el más eficaz sistema de gobierno —la república democrática— que necesita que madure y crezca en el espíritu popular, ya que, nosotros los ciudadanos, debemos ser los guardianes de los fines del Estado y no simplemente espectadores, ya que no se puede exigir aquello que nosotros mismos no hemos cumplido.

PARTE SEXTA

FORMAS DE ESTADOS

~

Todos los derechos reservados

188

CAPITULO I

LAS FORMAS DE ESTADO Y LAS FORMAS DE GOBIERNO

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Formas de gobierno. a) Formas históricas. b) Clasificaciones contemporáneas. c) Las formas de la democracia constitucional. d) Parlamentarismo. e) Presidencialismo. f) Semipresidencialismo. g) Hiperpresidencialismo. — 3. Formas de Estado. a) Introducción. b) La democracia, ¿forma de Estado o forma de gobierno? c) El federalismo. c.1) Nociones. c.2) Principios que lo informan. c.3) El federalismo argentino comparado con el de los Estados Unidos.

1. INTRODUCCIÓN

Para un Estado, es esencial diseñar una forma de Estado y de gobierno, pues con ellas se determina la organización política de un país en un momento determinado, además de servir para las generaciones futuras.

La mayoría de las constituciones contemporáneas se dividen estructuralmente en dos partes: la primera, dogmática (declaración de derechos y garantías), y una segunda parte, orgánica (donde se establecen cómo se distribuyen las atribuciones de cada uno de los poderes del Estado).

La forma de gobierno es la garantía por excelencia del goce de los derechos humanos, pues sólo cuando el poder del estado se distribuye entre diferentes órganos se establece un sistema de controles eficaces, para que de esa forma los derechos consagrados en la Constitución y en las normas internacionales tengan vigencia real y efectiva.

En las democracias contemporáneas se regulan dos aspectos esenciales. El primero es la noción de Estado de derecho social y constitucional, donde los gobernantes están sujetos a la Constitución y a las leyes y a los derechos humanos (sociales). Y por otro lado, la soberanía popular que permite el ascenso de la democracia y el reemplazo de la unanimidad por el debate y el respeto de las minorías, y no tan solo a lo dicho por la mayoría sino a las expresiones de todos los grupos sociales de un Estado. La democracia no nace del Estado de derecho sino del llamado a unos principios éticos —liber-

109

tad, justicia—en nombre de la mayoría sin poder y contra los intereses dominantes (1).

Empero, fueron las teorías expuestas en el siglo XVII y XVIII por Locke y Montesquieu sobre la separación de poderes las que suministraron las bases para los principios de la organización de las democracias con los valores propugnados y la organización del poder. Al respecto, no debemos olvidar que sin la presión del control de los ciudadanos y de los restantes poderes del Estado la democracia se transforma rápidamente en oligarquía.

Y justamente la separación del poder y la protección de los derechos humanos, son las que evitan la acumulación en un solo detentador del poder de las múltiples funciones y que los derechos más elementales del ser humano no sean normas sin funcionamiento sino, por el contrario, dotadas de un movimiento propio y eficaz que los haga llegar verdaderamente a todas las personas.

Si bien el art. 1º de la Constitución Nacional establece que nuestro país adopta—siguiendo principalmente el esquema diseñado por la Constitución de EE.UU.—para su gobierno la forma: 1) Representativa, 2) Republicana, y 3) Federal; se deja constancia que esta última no es una forma de gobierno, sino una forma de Estado.

2. FORMAS DE GOBIERNO

a) Introducción histórica a las formas de gobierno

Como bien expresa Karl Loewenstein (2), la ciencia política comenzó clasificando a las formas de gobierno en la antigua Atenas.

Esa reflexión inicial sirve para destacar la importancia del tema en tratamiento, que tiene que ver con un intento del ser humano de poner "cierto orden conceptual", en el caos que muchas veces muestra la realidad política cotidiana. Cada autor relevante dentro de la historia de las ideas políticas ha querido dejar su impronta, su sello personal, legándonos una clasificación más, aunque todas son hijas, en mayor o en menor medida, de la primera, que rastreamos en Aristóteles.

La desagregación aristotélica de "formas puras" y de "impuras" tuvo el mérito de combinar o de fusionar un criterio cuantitativo (cuántos detentadores de poder existen en un gobierno dado) con uno cualitativo (si ellos apuntan al bien común, o se encaminan o dirigen al bien personal o sectorial) (3), fruto

(1) TOURAINE, ALAIN, *¿Qué es la democracia?*, 1995, p. 35, citado por ONAINDIA, JOSÉ MIGUEL, *Instituciones del Derecho Constitucional*, 2004.

(2) V. LOEWENSTEIN, KARL, *Teoría de la Constitución*, Barcelona, 1979, p. 41.

(3) V. CARNOTA, WALTER F., y MARANIELLO, PATRICIO A., *Participación Ciudadana*, El Derecho Colección Académica, Buenos Aires, 2006, p. 19. Algunos sustituyen democracia radical, por

del realismo que cultivaba este autor. Así, el estagiano distinguía entre la monarquía, la aristocracia y la democracia, según gobernasen uno, pocos o muchos para el bienestar general ("formas puras"), y la tiranía, la oligarquía y la democracia radical (u "oclocracia") como formas "impuras" o corruptas de las anteriores, en la medida en que gobiernan uno, pocos o muchos para su propio provecho (4).

Con el tiempo, Polibio (que en realidad, era griego, pero había sido vendido a Roma como esclavo, transformándose ésta en su patria de adopción), retoma esta clasificación aristotélica, pero infundiéndole dinamismo y movimiento. Así, las formas políticas se van sucediendo, en ciclos políticos ("anacyclosis"), dado que cada forma de gobierno contiene en sí el germen de su propia destrucción, prueba de que no hay realizaciones humanas (y, por ende, políticas) eternas. En su exaltación a la Constitución de la Roma republicana, Polibio elige un gobierno mixto (5), que contuviese el principio *monárquico* (que cree discernir en el consulado romano), el *aristocrático* (en su Senado) y el *democrático* (en los diferentes "comitia").

En los albores de la Modernidad, Maquiavelo distinguía entre *principados* y *repúblicas* (6), con lo cual va a dejar para la posteridad una distinción que se va a repetir muchas veces en otros autores (7).

Por su parte, Montesquieu diferencia entre la *naturaleza* de cada gobierno—lo que le hace ser—, de su *principio*. El gobierno se divide en republicano (se subdivide en república democrática y república aristocrática), monárquico y despótico. Los principios son, respectivamente, la virtud, la moderación, el honor y el temor (8).

b) Clasificaciones contemporáneas

Claro que, con nueva cita de Loewenstein, es dable constatar que muchos de esos distingos tienen menos relevancia para un Estado constitucional, es decir, para un Estado que ha puesto en el centro de su vida político-institucional

demagogia. V. FAYT, CARLOS, *Historia del Pensamiento Político* ("La Antigüedad y el Medioevo"), Buenos Aires, 2004, tomo I, p. 22. Otros autores utilizan otras traducciones, reemplazando democracia por politeia, y demagogia u oclocracia por democracia. V. CHEVALLIER, JEAN-JACQUES, *Histoire de la Pensée Politique*, Paris, 1983, t. I, ps. 95 y sigtes.

(4) En definitiva, nótese que para Aristóteles, la cuestión del gobierno monárquico, aristocrático o democrático, y su jerarquía, es "secundaria", ya que el "régimen moderado" es mejor que el "excesivo". V. CHATELET, FRANÇOIS; DUHAMEL, OLIVIER y PISIER-KOUCHNER, EVELYNE, *Histoire des Idées Politiques*, Paris, 1982, p. 11.

(5) Ver CARNOTA, WALTER F., y MARANIELLO, PATRICIO A., *Participación Ciudadana*, op. cit., ps. 20/21.

(6) V. CHEVALLIER, JEAN-JACQUES, *Los grandes textos políticos desde Maquiavelo a nuestros días*, Madrid, 1977, p. 12.

(7) De todas maneras, no nos olvidemos que Maquiavelo no elabora una teoría del Estado, sino que el Estado para él es "un dato, un ser al que no pretende explicar como filósofo". V. TOUCHARD, JEAN, *Historia de las Ideas Políticas*, Madrid, 1975, p. 205.

(8) V. TOUCHARD, op. cit., ps. 309/310.

nal a la Constitución, con las características asignadas por el constitucionalismo moderno o clásico: escrita, rígida, suprema. Para este autor, las formas históricas de catalogar a los gobiernos se revelan insuficientes, al "dejar de lado la propia dinámica del proceso del poder" (9). Es que, en la misma línea, se ha dicho que "las tradicionalmente clásicas de monarquía, aristocracia y democracia han perdido crédito y realismo. Si acaso subsisten, se inoculan, esfuman o mimetizan en cualesquiera de las formas que hoy aparecen en las clasificaciones" (10).

Es decir, y en tren de matizar conceptos, el sempiterno problema de ¿cuántos gobiernan?, pasa a un segundo plano, asumiendo trascendencia de la cuestión de ¿cómo se gobierna?: si un gobierno responde a la tipología constitucional ("democracia constitucional"), o si, por el contrario, se estructura bajo otros parámetros ("autocracia"), en clave de realismo y de sociología constitucional. Para Loewenstein, el "principium divissionis" de estas dos formas pasa por el ejercicio distribuido o concentrado del poder, y por la presencia (o ausencia) de controles sobre el mismo (11).

Si bien han pasado más de cuarenta años de la formulación del Profesor de Armherst, no dejamos de computar la incidencia que en los estudios político-constitucionales ha tenido esta visión del problema.

c) Las formas de la democracia constitucional

Loewenstein establece que "...la conformación del poder es triangular: parlamento, gobierno y pueblo. El poder político está distribuido entre varios detentadores del poder que, por lo tanto, están sometidos a un control mutuo. Desde las revoluciones del siglo XVIII se han formado dentro de esta referida estructura diversos tipos que se diferencian entre ellos según qué detentador del poder ostente una situación preponderante. Sin embargo, los tipos puros son relativamente raros. Son más frecuentes, por lo tanto, los casos presentando combinaciones sincréticas en las cuales un determinado tipo adopta rasgos característicos de otros. Estos préstamos que ciertos tipos realizan de otros dificultan frecuentemente la clasificación de un régimen político concreto bajo determinado tipo de gobierno. Además, entre los diversos tipos de gobierno asignables al sistema político de la democracia constitucional no hay ninguno que pueda pretender ser 'el mejor' en el sentido de que sea el tipo adecuado para todas las naciones. La preferencia de una nación por un determinado tipo parece estar relacionada misteriosamente con sus tradiciones y experiencias, como por ejemplo la tendencia de los alemanes a formar un poder ejecutivo fuerte y la fuerza de atracción que el gobierno de asamblea ejerce en los franceses..." (12).

(9) V. LOEWENSTEIN, KARL, op. cit., p. 45.

(10) V. BIDART CAMPOS, GERMÁN J., *Teoría del Estado (Los temas de la Ciencia Política)*, Buenos Aires, 1991, p. 90.

(11) V. LOEWENSTEIN, KARL, op. cit., p. 51.

(12) *Teoría de la Constitución*, op. cit., p. 91.

El mismo autor agrupa los diferentes tipos de gobierno de la democracia constitucional en seis categorías diferentes:

1. la democracia directa;
2. el gobierno de asamblea;
3. el gobierno parlamentario, que a su vez subdivide en clásico, híbrido, controlado y frenado, de acuerdo a diversas conformaciones históricas;
4. el gobierno de gabinete;
5. el presidencialismo;
6. el gobierno directorial, que es un tipo "sui generis" de Suiza.

Aunque en la actualidad es muy difícil encontrar una forma de gobierno pura, por lo que la mayoría de los países siguen la forma mixta, expondremos las dos formas clásicas: parlamentarismo y presidencialismo, y a su vez haremos alusión a la forma semi-presidencialista y al hiper-presidencialismo.

d) Parlamentarismo

Esta es la forma típica de organización de los países europeos y que también ha sido adoptado por anteriores colonias europeas.

Es casi una obviedad decir que en ellas el poder central está en el parlamento, aunque debe existir un *equilibrio* en el ejercicio de funciones del poder, que en este caso son: ejecutivo y legislativo o gobierno y parlamento.

El pueblo es quien elige a los integrantes del órgano legislativo a través del sufragio popular y está prevista la posibilidad de la interrupción de los mandatos de sus miembros, por medio de la disolución de la asamblea, mientras que los miembros del gabinete generalmente son elegidos por el parlamento y su titular es el jefe del partido o coalición con mayoría de representación parlamentaria.

La característica más importante es que el ejecutivo no lo ejecuta una sola persona sino que es dual. La jefatura de Estado es desempeñada por un monarca sujeto a las normas constitucionales (España, Bélgica, Holanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, etc.) o el presidente en las repúblicas constitucionales (Italia, Alemania, Austria), cargo que tan solo tiene un valor *simbólico*, cuyas funciones no se caracterizan por traducir un ejercicio efectivo del poder. Por otro lado, la jefatura de gobierno y, por ende, el manejo ordinario de las políticas se le asigna a un Primer Ministro, denominado Jefe de Gobierno o Presidente de Gobierno (v.gr. España), es elegido por el Parlamento y ambos deben tener un vínculo muy cercano, con los ministros que incluso llegan a integrar también el Parlamento (proximidad que Loewenstein identifica como principio motor de esta forma, que denomina "interdependencia por integración"). El "premier" agrupa el poder político del ejecutivo y lidera el resto del gabinete, constituyéndose en el centro *real* del poder.

Los instrumentos más característicos de autocontrol son dos: la *moción de censura*, donde el parlamento puede expresar su insatisfacción con el gabinete en su conjunto o con alguno de sus miembros produciendo así la separación del cargo y su reemplazo por otro gabinete; con esta herramienta, el órgano legislativo exige la responsabilidad política del ejecutivo. Y por otro lado, encontramos la llamada *disolución de la asamblea* y el llamado a nuevas elecciones, resultando de tal forma el cuerpo electoral quien decida la confrontación entre ambos órganos de gobierno.

Para Loewenstein, el derecho de disolución del parlamento y el voto de no confianza están juntos como "el pistón y el cilindro en una máquina...". Su respectivo potencial hace funcionar las ruedas del mecanismo parlamentario. Allí donde estas respectivas facultades no se correspondan adecuadamente, no puede funcionar un sistema parlamentario auténtico, pues en un caso se producirá una supremacía del órgano legislativo por el debilitamiento del gobierno y en otro, si existe una limitación sería de la moción de censura se producirá una situación de preponderancia del gobierno sobre el parlamento. Ambas situaciones producen el desequilibrio del sistema y su reemplazo por alguna otra forma de gobierno, que no se compadece con el espíritu del parlamentarismo (13).

e) Presidencialismo

Se establece por primera vez en la Constitución Norteamericana de 1787, para luego incorporarse a las restantes constituciones de América y del mundo. La citada Constitución norteamericana ha sido la creadora de esta forma de gobierno, y ha perdurado ininterrumpidamente por más de 200 años.

Si bien una de las características más importante es la división de poderes, Karl Lowenstein utiliza el término "funciones" en lugar de "poderes", para designar los ámbitos o esferas que cumplen cada uno en la actividad pública. La técnica de los miembros de la Convención de Filadelfia fue la de distribuir las funciones del Estado en diversos detentadores del poder, que deben realizar la gestión de gobierno mediante relaciones de coordinación. "...Para alcanzar ese objetivo fueron utilizados dos principios diferentes y hasta cierto punto contradictorios. De acuerdo con la teoría constitucional dominante, las actividades estatales fueron divididas en tres campos separados, cada uno de ellos asignado a un 'body of magistracy': el ejecutivo al presidente, el legislativo al Congreso y el judicial a los tribunales. En cada uno de estos campos se concedió al respectivo detentador del poder autonomía y monopolio de acción, no pudiendo ser violado este ámbito por ninguno de los otros detentadores del poder. Este fue el principio de la especialización en el ejercicio de las funciones estatales asignadas. Sin embargo, como se era absolutamente consciente de que un aislamiento rígido de las funciones conduciría necesariamente a bloqueos permanentes entre los diferentes detentadores del poder, paralizando así el proceso político, se exigió que en ciertos

'puntos de contacto', exactamente determinados, los detentadores del poder independientes deberían ser de tal manera coordinados, que sólo a través de su cooperación alcanzaría validez constitucional la específica actividad estatal asignada al correspondiente detentador del poder..." (14).

En el presidencialismo, sobre la base de ese principio de "interdependencia por coordinación", el poder se divide en tres: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Aunque en la República Argentina luego de la reforma constitucional de 1994 con el art. 120 se ha considerado por algunos al Ministerio Público como otro poder del Estado. Cada uno de ellos tiene funciones propias, y concurrentes, además de funciones de control mutuo.

El Poder Ejecutivo es unipersonal porque reúne en un mismo órgano (el Presidente) las jefaturas de Estado y de gobierno, desempeñando de tal forma la representación jurídica de la nación y el manejo de la administración. Su mandato proviene del sufragio popular, cualquiera sea el sistema de elección que se adopte, y tiene una extensión fijada por la Constitución y sin intromisión de ningún otro poder. La posibilidad de destitución por juicio político es una derivación de las relaciones de control que el sistema establece y que contrariamente a lo que su nombre indica no implica una valoración política de sus acciones sino un juicio de responsabilidad sobre sus conductas (mal desempeño). Los ministros son órganos auxiliares del Presidente sin integrar el ejecutivo y resultan dependientes de la decisión de aquél, tanto para su designación y remoción como para la instrumentación de las acciones de gobierno que le propongan. Si bien no en todos los regímenes presidenciales encontramos la figura del vice-presidente, cuando está contemplada no integra el órgano ejecutivo y se le reconocen funciones muy limitadas.

El Congreso tiene sus facultades exclusivas de legislación y es el órgano de la representación popular plural. Como órgano colegiado es frecuente que su renovación sea periódica y parcial y que tanto la elección de sus miembros como la extensión de sus mandatos no coincidan con el previsto para el órgano ejecutivo. Esta circunstancia torna más delicado el equilibrio y la coordinación entre ambos órganos, porque el Congreso puede tener composiciones que no sean idénticas a las preferencias del electorado para la selección del presidente (15).

El Poder Judicial tiene también funciones propias y de constitucionalidad, ejerce el control de legalidad a través de lo que denominamos la jurisdicción constitucional: vela por el respeto del principio de supremacía de la constitución y puede mediante la declaración de inconstitucionalidad quitar validez a los actos de los restantes órganos.

Una mención expresa merece el presidencialismo desarrollado en Iberoamérica, pues por características diversas al modelo racional-normativo ha tomado una configuración particular y ha desvirtuado en la práctica sus as-

(13) Op. cit., p. 107.

(14) Op. cit., p. 132.

(15) ONAINDIA, JOSÉ MIGUEL, op. cit.

pectos republicanos. Nogueira Alcalá sostiene que el presidencialismo latinoamericano fue llamado por cierta corriente doctrinaria como "cesarismo representativo" pues en caso de buen funcionamiento se diferencia de la dictadura porque no tiene carácter ilimitado, proviene de una elección popular y tiene un mandato limitado en el tiempo. El análisis que efectúa el autor citado demuestra que en la práctica el ejecutivo ha acumulado tantas funciones que se produce un marcado desequilibrio del principio de separación de poderes que es la base del modelo originario. Las facultades co-legislativas del Presidente en América Latina han producido una concentración de funciones en detrimento del órgano legislativo, que han causado también su frágil gobernabilidad (16).

f) El semi-presidencialismo

Maurice Duverger considera una nueva forma de gobierno que la llama "semi-presidencialismo", mientras que Loewenstein lo denomina "parlamentarismo frenado" y lo analiza dentro de los sub-tipos del parlamentarismo. Los antecedentes los podemos encontrar en la Constitución de Finlandia de 1911, y en la Constitución de la V República de Francia.

Las características de este sistema es la siguiente:

- un Primer Ministro, quien ejerce las funciones de jefe de gobierno y es elegido por el Parlamento;
- un Presidente de la República. Este órgano es unipersonal y es de carácter electivo, porque debe ser elegido por sufragio universal y tiene un mandato determinado. Ejerce la jefatura de Estado pero tiene también competencias propias que lo diferencian de los regímenes parlamentarios.

En Francia se le da como función ser el custodio de la Constitución garantizando la unidad y continuidad nacional:

- el Parlamento, dotado de la moción de censura pero también sujeto a la posibilidad de disolución que se le concede al Presidente;
- control político de constitucionalidad (en el caso francés), que regula un control previo de constitucionalidad de determinadas normas y se otorga a un organismo que no integra el órgano jurisdiccional (17).

g) Hiper-presidencialismo

A lo largo de las últimas dos décadas, ha habido cuantiosa literatura politológica y constitucional que ha hecho referencia al "hiper-presidencialismo", como p.ej. en América Latina, África y Asia. El "hiper-presidencialismo"

se muestra como una forma corrompida o degenerada del presidencialismo. En efecto, como ya vimos, lo característico de este último es la prolífica delimitación de incumbencias a cargo de cada uno de los órganos del poder del Estado. Si se quiere, la división de poderes es más férrea.

Por el contrario, en la versión hiper-presidencialista, todos los órganos del poder se encuentran satelizados o verticalizados a la omnímoda voluntad presidencial. Es un fenómeno más sociológico-político que normativo, aunque hay constituciones que lo favorecen permitiendo el ejercicio de funciones legislativas y la reelección indefinida del titular de la presidencia.

Como sea, esta forma se halla signada por una suerte de "patrimonialización" de la política, en donde se difuman las fronteras del espacio público y del privado, y en donde los controles a ese poder son nulos o casi inexistentes.

3. FORMAS DE ESTADO

a) Introducción

Cuando nos detenemos en el análisis de las *formas de Estado*, indagamos —según Bidart Campos— dos problemas. En efecto, relacionamos al elemento poder político con el territorio, con lo cual obtenemos formas de Estado centralizadas y descentralizadas, y con la población, con lo que observamos formas de Estado democráticas y no democráticas.

b) La democracia, ¿forma de Estado o de gobierno?

Nótese, de modo liminar, que Bidart Campos conceptualiza a la *democracia* como forma de Estado y no de gobierno (18), como vimos que propone Loewenstein, por entender que el estilo de vida democrática hace a un modo estructural de organizarse la relación de los seres humanos con el poder público, que reconoce sus derechos y libertades fundamentales. Por el contrario, las formas no democráticas desconocen estos derechos, dice el autor argentino, subdividiendo en autoritarismos (cuando hay restricción) y en totalitarismos (cuando hay directamente negación de los mismos).

En tren de matizar todos estos conceptos, nosotros entendemos que la democracia es a la vez forma de Estado y forma de gobierno. Es que el hecho que la democracia sea relacionada con la participación ciudadana volcada en determinados procesos electorales no es ni antitética ni contradictoria con la proposición de un Estado en donde se respeten los derechos y garantías de las personas. Ambas concepciones se integran armónicamente.

(16) SABSAY-ONAINDIA, *La Constitución de los Argentinos*, 2000, p. 178.

(17) ONAINDIA, JOSÉ MIGUEL, op. cit.

(18) Desde su tesis doctoral en 1953. Ver, por todas sus obras, BIDART CAMPOS, GERMÁN J., *Derecho Político*, Buenos Aires, 1962, ps. 391/392; ídem, *Lecciones Elementales de Política*, Buenos Aires, 1973, p. 240, entre otras.

c) El federalismo

c.1) Nociones

También se debe al genio político de la Constitución Norteamericana la vertebración de una nueva relación del poder político con el territorio, que es el federalismo. Si bien se trata de una forma política *descentralizada*, aclara Manuel García Pelayo que se trata de una "unidad dialéctica de dos tendencias contradictorias: la tendencia a la unidad y la tendencia a la diversidad" (19).

Debe resaltarse que como bien apuntaba Kelsen, la descentralización política es cuestión de grados. Generalmente, como p.ej. aconteció en Estados Unidos y en la Argentina, primero las entidades se reunieron en una confederación, y recién con posterioridad, en un Estado federal. Recuérdese que la confederación es una unión de Estados mucho más laxa (20), que se diferencia del Estado federal, toda vez que sus partes integrantes tienen derecho de veto o nulificación (es decir, no aceptar una decisión emanada del órgano confederal), y de secesión (o sea, de separarse del conjunto).

El federalismo implica la existencia de dos gobiernos con claros ámbitos competenciales: uno federal, o central, y otros tantos gobiernos provinciales o estatales, dotados de *autonomía*, es decir, la capacidad de dictarse sus propias normas. Así, en el derecho constitucional comparado, estados (Estados Unidos, Brasil, México), provincias (Argentina, Canadá), cantones (Suiza), Landier (Alemania), coexisten al lado de un gobierno "federal".

Se diferencia el concepto de *autonomía*, como potestad de auto-normarse, de la categoría de la *autarquía*, que conlleva una noción de autogobierno. En Argentina, son autónomas las provincias (art. 123), pero también lo es la Ciudad de Buenos Aires, a tenor de lo normado por el art. 129 que le imprime la característica de "estado sui-generis" ya que no llega a ser una provincia más.

Hoy en día el llamado "derecho constitucional subnacional" o "derecho constitucional provincial" se ha desarrollado vertiginosamente, a la par de mayores demandas de descentralización, de reafirmación de identidades socio-culturales (como aconteció en Bélgica, que se transformó en Estado federal en 1993) y de desburocratización del poder ("*devolution*").

El federalismo supone una descentralización del poder, resultando la forma antitética del Estado unitario (Chile, Colombia). En la actualidad, se conforman Estados unitarios con algún margen de descentralización (Francia, Reino Unido), o con considerables grados de ella, que llegan a ser conceptuados como Estados regionales o incluso "federo-regionales" (v.gr. Italia y España).

(19) V. GARCÍA PELAYO, MANUEL, *Derecho Constitucional Comparado*, Madrid, 1999, p. 218.

(20) En donde el poder central es más limitado. V. GONZÁLEZ MADRID, "Federalismo vs. Unitarismo", en EMMERICH, GUSTAVO E., y ALARCÓN OLGUÍN, VÍCTOR (Coordinadores), *Tratado de Ciencia Política*, Barcelona, 2007, p. 154.

c.2) Principios que lo informan

Hay tres principios que son fundamentales en todo Estado federal. El *principio de supremacía federal* significa que, más allá que las provincias puedan dictarse sus propias constituciones (art. 123), lo deben hacer con arreglo y de conformidad con la Constitución Federal (arts. 5º, 31, 123 cit. y conc., de la Constitución Argentina).

Por su parte, el *principio de coordinación* supone un desglose o distribución de competencias entre la federación y las entidades locales. Nuestra Constitución prevé en su art. 121 que lo no delegado expresamente al gobierno central, queda reservado a las provincias. Por último, el *principio de participación* supone que en la estructura del poder central, las provincias tienen intervención con voz propia, como acontece en nuestra dogmática constitucional con el Senado. Repárese que, de todos modos, no todos los Estados federales tienen bicamarismo (Venezuela, St.Kitts-Nevis).

c.3) El federalismo argentino comparado con el de los Estados Unidos

Las historias de los federalismos argentino y norteamericano no son idénticas ni lineales. Diversas tradiciones coloniales, distintas matizaciones en el espíritu revolucionario y disímil período confederal, fueron todas coordinadas que fraguaron en textos que a primera vista resultan parecidos, pero que no lo son tanto.

Más allá de la notoria influencia que ejerció la Constitución norteamericana de 1787 sobre la Argentina, no puede decirse que esta última haya sido una "copia" de la primera (21). Amén del federalismo norteamericano, el constituyente de 1853 tuvo presente la historia vernácula. Además, la inspiración constitucional de Alberdi—quien abogaba por una forma "mixta"—tuvo profunda incidencia en el momento constitucional originario.

Es recién la apodada "reforma" de 1860 que logra introducir algunos elementos mayores de descentralización en el texto primigenio. Por lo demás, nuestra Constitución no registra una cláusula como la Enmienda XI agregada al documento de Filadelfia en el año 1798 (22) (23).

(21) V. CARNOTA, WALTER F., "El federalismo judicial argentino en clave comparada con el de los Estados Unidos", en CARNOTA, WALTER F., (Director), *Derecho Federal (Sus implicancias prácticas)*, Buenos Aires, 2005, ps. 14/15.

(22) *Ibidem*.

(23) Enmienda XI: "... no se interpreta que el Poder Judicial de los EE.UU. se extiende a cualquier litigio en derecho o en equidad que se inicie o se prosiga contra alguno de los estados unidos por ciudadano de otro estado, o por ciudadanos o súbditos de un estado extranjero...".

199

PARTE SÉPTIMA

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

~

Todos los
Derechos

195

CAPITULO I

EL HABEAS DATA EN EL MUNDO INFORMÁTICO (SU AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL) (*)

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Relevancia del tema. — 3. Regulación nacional y provincial. — 4. Interpretación en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. — 5. Definición conceptual. — 6. Derechos protegidos. — 7. Objetivos y subtipos. — 8. Procedimiento. a) Carril procesal. b) Legitimados. c) Competencia. — 9. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

El instituto del "habeas data" tiene una etimología mixta, por la que se conjuga la unión de dos palabras de origen y de desarrollo diferentes.

El vocablo "habeas" proviene del latín "habere", que significa "téngase en su posesión" o "tráigase", y "data", se origina para una corriente en el inglés que significa datos, definido por los diccionarios como representación convencional de hechos, conceptos o instrucciones de forma apropiada para la comunicación y procesamiento por medios automáticos. Por lo que "habeas data" quiere decir "que tengas los registros, los datos" (1).

Como ya adelantásemos, ambos vocablos tienen orígenes y desarrollos diferentes, pero en forma conjunta el "habeas data" se conoció por primera vez en la ley de Río de Janeiro N° 824, para luego volcarse en el art. 5° de la

(*) Sobre la base de la exposición de los autores en el VI Seminario de Derecho Procesal Civil y Comercial Profundizado, Posgrado de la Universidad de Morón, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 16 de noviembre de 2004.

(1) En la doctrina comparada hay unanimidad en que la formulación "habeas data" se origina parcialmente del habeas corpus, pero mucho se ha discutido con respecto a la significación de la palabra data. Con referencia a esta última, existen dos vertientes, una según la cual "data", es un acusativo neutro plural de datum, de la misma raíz que el verbo latino do, das, dedi, datum, dare, 'dar', 'ofrecer'. Datum, singular de data, es empleado (*omissis*) con el sentido de presentes, donativos, ofertas, y no con el sentido de datos". La vertiente contraria sostiene que la palabra data proviene del inglés, "posición que encuentra como fundamento el hecho de haber sido utilizado en tal sentido por la Data Protection Act de Inglaterra, la Data Lag de Suecia, la Federal Data Protection Act de Austria, entre muchas otras...". (DDG-167-01. 16/7/2001. Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela).

consultación brasileña de 1988 (2). El procedimiento se desvirtúa a través del conocido "mandato de segurança" (equivalente a la acción de amparo en Argentina), conforme el mismo artículo.

Luego fue incorporado en las Constituciones de Paraguay (3), Colombia, Perú (4), entre otras, y finalmente en la Argentina, con la reforma de 1994 (art. 43), aunque sin dicha denominación, pues "habeas data" ha surgido de la doctrina.

En cuanto a su naturaleza, sabemos que el habeas data es una garantía constitucional. Un primer interrogante a formular ha consistido en determinar si es una acción autónoma o una vertiente específica del amparo, sobre todo en atención a los términos de la ley 24.309 de necesidad de la reforma, cuyo art. 3º inciso n) no menciona al "habeas data" sino sólo al amparo y al "habeas corpus".

2. RELEVANCIA DEL TEMA

El abordaje propuesto vincula la garantía de habeas data, en su específica relación con los desafíos que plantea el horizonte informático en el mundo contemporáneo.

Cada época histórica ha tenido una garantía paradigmática. Así como el primer constitucionalismo, también llamado clásico o liberal, que tiene inicio en el siglo XVIII, estuvo signado por la preocupación de la libertad física de las personas tutelada por el "habeas corpus", la expansión de los derechos registrada bajo el ropaje del constitucionalismo social del siglo XX desemboca en el auge del amparo.

Dentro de este contexto, y como un amparo específico o especializado, es que surge la acción de "habeas data".

Las últimas décadas del siglo XX y los comienzos del siglo XXI plantean nuevos desafíos para el derecho constitucional. Concretamente, la Constitución debe hacerse cargo (tal como ocurrió con nuestro art. 43 agregado como fue dicho en 1994) de nuevas situaciones que potencialmente puedan herir o vulnerar dramáticamente diversos derechos subjetivos. Hoy en día vivimos

(2) Brasil: art. 5º, inc. LXXI. Se concederá "habeas data": a) para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona del impetrante que conste en registros o bancos de datos de entidades gubernamentales o de carácter público; b) para la rectificación de datos, cuando no se prefiera hacerlo por procedimiento secreto, judicial o administrativo.

(3) Paraguay: Art. 135. — Toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización, rectificación, o la destrucción de aquéllos, si fuesen erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos".

(4) Perú: Art. 200. — Son garantías constitucionales... 3) La acción de habeas data, que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el art. 2, incs. 5, 6 y 7, de la Constitución".

es sencillamente una parte sustancial del juego del poder. Se ha afirmado con razón que "la información se convierte en la materia prima de las relaciones económicas, sociales y culturales, dando ventajas competitivas a quien dispone de información y convirtiéndola en una estrategia para el mercado globalizado, por lo que información equivale a poder" (5).

Cabe destacar que tal como consigna Eloy Espinosa (6), existen en el ámbito del derecho constitucional comparado tres maneras distintas de tutela en materia de "habeas data", a las que clasifica como "modelo norteamericano", "modelo europeo" y "modelo latinoamericano". El primero, a través de disposiciones legales como la F.O.I.A. ("Freedom of Information Act") de 1966 y la "Privacy Act" de 1974, busca una protección jurisdiccional a diversos aspectos de la autodeterminación informativa. El segundo, al que contribuyeron legislaciones señeras como la ley del land de Hesse de 1970, la sueca de 1973 y la inglesa de 1984, se orienta entre otras facetas a las labores tuitivas que puedan desplegar entidades especializadas. En Latinoamérica, la protección se verifica por medio de medios procesales específicos.

3. REGULACIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL

En el ámbito nacional, el 'habeas data' ("que tengas los registros, los datos") se halla consagrado, tal como se anticipó, en el art. 43 CN, tercer párrafo, que expresa: "Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ellos referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística".

También ha sido incorporado a casi todas las constituciones provinciales. Así, por ejemplo:

Buenos Aires. Art. 20. — "Se establecen las siguientes garantías de los derechos constitucionales.... A través de la garantía de habeas data que se registrá por el procedimiento que la ley determine, toda persona podrá conocer lo que consta de la misma, en forma accesible, actualizada y confidencial, los datos de organismos públicos o privados destinados a proveer informes, así como la finalidad a que se destine esa información, y a requerir su rectificación, actualización o cancelación. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística".

Ningún dato podrá registrarse con fines discriminatorios, ni será proporcionado a terceros, salvo que tengan un interés legítimo. El uso de la informática no

(5) V. ALLIARANGUREN, JUAN-CRUZ, *Derecho Administrativo y Globalización*, Valencia, 2004, p. 246.

(6) V. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, ELOY, *Código Procesal Constitucional*, Lima, 2004, ps. 57 y sigtes.

197

podrá vulnerar el honor, la intimidad personal y familiar, y el pleno ejercicio de los derechos”.

Chaco: Art. 19. — “... Toda persona tiene derecho a informarse de los datos que sobre sí mismo, o sobre sus bienes, obren en forma de registros o sistemas oficiales o privados de carácter público; la finalidad a que se destine esa información, y a exigir su actualización, corrección, supresión o confidencialidad.

Tales datos no podrán ser utilizados con fines discriminatorios de ninguna especie.

No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística...”.

Córdoba: Art. 50. — “Toda persona tiene derecho a conocer lo que de ella conste en forma de registro, la finalidad a la que se destine esa información, y a exigir su rectificación y actualización. Dichos datos no pueden registrarse con propósitos discriminatorios de ninguna clase, ni ser proporcionados a terceros, excepto cuando tengan un interés legítimo. La ley reglamenta el uso de la informática para que no se vulneren el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos”.

En forma similar está contemplado en las provincias de San Luis, San Juan, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Catamarca, entre otros ordenamientos jurídicos.

4. INTERPRETACIÓN EN EL SISTEMA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Cabe apuntar que la Convención Americana de Derechos Humanos (o “Pacto de San José de Costa Rica”) tutela aisladamente los derechos de intimidad (art. 11, párrafo segundo), de libertad de expresión (art. 13) y de rectificación o respuesta (art. 14). El arsenal garantístico compuesto por los arts. 8º y 25 no menciona puntualmente al “habeas data”.

Ahora bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión de 1999, respecto del habeas data se pronunció en los siguientes términos: “(...) Mediante este procedimiento se garantiza a toda persona acceder a información sobre sí misma o sus bienes contenida en bases de datos o registros públicos o privados y, en el supuesto de que fuera necesario, actualizarla o rectificarla. Esta acción adquiere una importancia aun mayor con el avance de nuevas tecnologías. Con la expansión en el uso de la computación e Internet, tanto el Estado como el sector privado tienen a su disposición en forma rápida una gran cantidad de información sobre las personas. Paralelamente, la cantidad y velocidad en las comunicaciones hace más importante la existencia de canales concretos de acceso rápido a la información para modificar información incorrecta o desactualizada en los bancos de datos electrónicos”.

Es así como la Comisión resalta la importancia de esta acción frente a Internet y los avances tecnológicos, recomendando en este sentido que los Estados provean, dentro de su orden jurídico, procedimientos rápidos y eficaces para que el habeas data alcance su plenitud, a fines de garantizar el acceso a la información sobre su persona o sus bienes, que se encuentren contenidas en los registros o bases de datos.

5. DEFINICIÓN CONCEPTUAL

Varias definiciones se han dado con relación a esta acción. Es así como, en el derecho constitucional procesal o derecho procesal constitucional (según como prefiera nombrarse a este sector jurídico) se considera como una de las garantías constitucionales más modernas, precisándose de la siguiente manera: “Una acción judicial para acceder a registros o bancos de datos, conocer los datos almacenados y en caso de existir falsedad o discriminación corregir dicha información o pedir su confidencialidad, dando respuesta de esta forma transaccional a los derechos constitucionales de ‘registrantes’ y ‘registrados’”.

6. DERECHOS PROTEGIDOS

El promotor deberá alegar que los registros del caso incluyen información que es inexacta o que puede provocar discriminación, pero en ambos casos no es necesario establecer que ocasiona daño.

La ley 25.326 (7) que regula la protección de los datos personales, en su art. 1º establece los derechos que protege el habeas data: 1) el derecho al honor; 2) la intimidad de las personas y 3) el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el art. 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional. Las disposiciones de esta ley también serán aplicables, en cuanto resulten pertinentes, a los datos relativos a personas de existencia ideal. En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas.

Es que al considerar propiamente a esta acción, nos debemos interrogar primeramente cuál es el derecho o bien jurídico tutelado.

Debe señalarse que existe una estrecha conexión entre el derecho material, y el mecanismo garantístico ideado para su eficaz cumplimiento. En tal sentido, creemos que la trinidad de procesos urgentes es integrativa más de un “derecho constitucional procesal”, que de un “derecho procesal constitucional”, más allá que esta es la expresión de uso más corriente y frecuente. Delimitar dentro de esta problemática que es lo sustantivo y que es lo adjetivo, no es tarea fácil de llevar a cabo (8).

(7) B.O. 2/11/2000.

(8) V.CARNOTA, WALTER F., “La expansión del derecho procesal constitucional”, en: www.eldial.com.

...en el punto, nan existido diversas posturas. Se ha afirmado que "verdaderamente, el derecho a la intimidad (art.19, CN), aparece como la potestad subjetiva aquí protegida por excelencia. Pero la honra, la reputación, la imagen y hasta la libertad de información también están involucradas de manera decisiva. Es que, en definitiva, lo que aquí se protege es el *derecho a la autodeterminación informativa*. Aunque el art. 1º de la ley singularice al 'honor y a la intimidad de las personas' como derechos tutelados, no tenemos duda de que las diversas facetas cubiertas por la ley 25.326 dan margen suficiente para sostener que toda la canasta valorativa referida a la autodeterminación informativa encuentra aquí hospedaje, más allá de las menciones explícitas y concretas" (9).

7. OBJETIVOS Y SUBTIPOS

El habeas data nacional tiene cinco metas específicas: 1) acceder a la información; 2) rectificar las que resulten equivocadas; 3) actualizar los datos obsoletos; 4) suprimirlos; 5) asegurar su confidencialidad.

Como eco de lo que dispone el art. 43, tercer párrafo, de la Constitución Nacional, ya citado varias veces, el art. 33 de la ley 25.326 estima procedente a esta acción: a) para tomar conocimiento de los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes, y de la finalidad de aquéllos; b) en los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido en la ley, para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización.

Más allá de los desfases que se evidencian entre esta norma con el art. 1º del mismo cuerpo legal ya examinado, en una de las obras cumbres de la materia, se ha concluido que "cabe coincidir con Carnota en que el art. 33 incluye expresamente varios tipos de habeas data, recogiendo en tal sentido la clasificación aportada por Sagüés; en concreto, los habeas data informativo (subtipos exhibitorio y finalista), rectificador, exclutorio, reservador y actualizador" (10).

8. PROCEDIMIENTO

a) Carril procesal

El art. 43 de la Constitución Nacional ha instituido en virtud de dicha cláusula al habeas data como una acción de amparo especial que permite a toda persona tomar conocimiento de los datos o informaciones a ella referi-

(9) Énfasis original. Ver CARNOTA, WALTER F., "Visión de conjunto de la ley 23.526", en *Antecedentes Parlamentarios. Ley 25.326 Habeas Data*, Buenos Aires, 2000, p. 499.

(10) Ver PUCCINELLI, OSCAR R., *Protección de datos de carácter personal*, Buenos Aires, 2004, ps. 528/529.

dos o que la afecten o puedan afectarla, alterando o restringiendo indebidamente sus derechos, especialmente de intimidad y a la veracidad de su imagen, y una vez comprobada la inexactitud, falsedad, carácter discriminatorio o lo indebido de la difusión a terceros de los mismos, otorga al afectado la potestad, a través de la misma, de exigir su supresión, rectificación, modificación, actualización, o confidencialidad, según fuere al caso.

No toda la doctrina concuerda con la decisión constitucional de configurar al habeas data como una especie del amparo. Por citar un ejemplo, Altmark y Molina Quiroga (11), entienden respecto de ello que: "Al consagrar el habeas data, asimilándolo a la acción de amparo, se corre el serio riesgo de desvirtuar la finalidad del instituto. Mientras al amparo como remedio o vía procesal de naturaleza excepcional, requiere que exista 'ilegalidad o arbitrariedad manifiestas', el 'habeas data', en cambio, tiene una finalidad muy específica, que es otorgar a toda persona un medio procesal eficaz para proteger su intimidad, o evitar que terceras personas hagan un uso indebido de información de carácter personal que le concierne" (12).

En relación con la discutida cuestión de su naturaleza procesal, podemos distinguir en la doctrina dos posturas: la primera, que en atención a la regulación constitucional nacional, la entiende como una especie particular, dentro del género del amparo, sin que resulte alcanzada, a mérito de tal especificidad, por lo dispuesto en la primera parte del art. 43 (13). En tanto la segunda, distingue la figura por entero del amparo, la abastece de perfiles propios y de ribetes singulares (14).

b) Legitimados

La ley indica en su art. 34 quiénes pueden interponer la acción. Al respecto, señala como sujetos de legitimación activa al afectado, a sus tutores o curadores y a los sucesores hasta el segundo grado en línea directa o colateral, ya sea por sí o por apoderado. En el caso de las personas jurídicas, lo harán sus representantes legales o apoderados. Puede intervenir de manera coadyuvante el Defensor del Pueblo.

Creemos que, "contrariamente a las voces que sostenían, en una interpretación literalista del art. 43 CN, que sólo la persona afectada podía titularizar la acción, el perímetro subjetivo activo del habeas data —tal como propuso la mayoría de la Corte en 'Urteaga'— se ensancha" (15).

(11) *Informática y Derecho. Aportes de la doctrina internacional*, vol. 6, Régimen jurídico de los bancos de datos, Buenos Aires, 1998, p. 165.6.

(12) CARRANZA TORRES, LUIS, "Procedencia de las medidas cautelares en el Habeas Data". Copyright ©1998-2002 José Cuervo.

(13) Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Martínez c. Organización Veraz S.A." (sentencia del 5/4/2005, Fallos: 328:797, LA LEY, 13/4/2005, p. 7 y sigtes., ED, 20/5/2005, p. 4) expresó que no es necesario que a los fines de la acción de "habeas data" concurra la "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" necesaria en la acción de amparo.

(14) CARRANZA TORRES, LUIS, op. cit.

(15) V. CARNOTA, WALTER F., *Visión...*, op. cit., p. 501.

199

En efecto, en la sentencia "Urteaga, Facundo R." (resuelta el 15 de octubre de 1998, Fallos: 321:2767), el Alto Tribunal prescindió del "nomen iuris" y, ya se lo encarase como habeas data según la mayoría o como amparo especializado según la opinión minoritaria, lo cierto del caso es que aún sin encontrarse vigente la ley reglamentaria (16) entendió admisible la acción articulada por quien revestía la calidad de hermano de quien se suponía fallecido.

Sostenemos que la legitimación del Defensor del Pueblo es adhesiva y no originaria. Se refuerza el carácter "*intuitu personae*" de la acción y se reedita un recorte a las facultades del "Ombudsman" visto en varios antecedentes de la Corte Suprema en materia de amparo colectivo. Se marca una diferencia con la vetada ley 24.745 donde la competencia de la Defensoría era vasta (17).

Aparece bien delineada la legitimación pasiva, en cuanto la obligación es puesta en cabeza por el art. 35 de los responsables y usuarios de bancos de datos públicos y de privados destinados a proporcionar informes.

c) Competencia

En virtud de lo que prescribe el art. 36, párrafo primero, se privilegia al pretensor procesal, ya que la ley faculta a articular la acción ante el juez del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiere tener efecto, a elección del accionante.

La competencia federal procede en aquellas hipótesis que la acción se dirija contra archivos de datos públicos de organismos nacionales o interconectados en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales. Coincidimos en que se trata de una aplicación de la directiva de la "cláusula comercial" del art. 75 inc. 13, CN (18).

9. CONCLUSIONES

En lo que respecta al interrogante planteado, con relación a la autonomía adjetiva y sustantiva de la acción de habeas data, y más allá de las diversas opiniones doctrinarias compulsadas, es de resaltar que son dos los elementos determinantes para esclarecer la cuestión en debate: por un lado la sanción de una ley específica como es la ley 25.326 y por otro lado lo afirmado

(16) V. CARNOTA, WALTER F., "Enfoques sobre habeas data. Operatividad de tratados y reafirmación internacional. El fallo 'Urteaga'", en TRAVIESO, JUAN A., y otros, *Colección de Análisis Jurisprudencial. Derechos Humanos y Garantías*, Buenos Aires, 2002, p. 195.

(17) Idem nota núm. 14.

(18) V. ARRABAL DE CANALS, OLGA PURA, "La acción de habeas data en la ley nacional 25.326 (sus aspectos procesales)", en ARMAGNAGUE, JUAN FERNANDO (Director), *Derecho a la información, habeas data e Internet*, Buenos Aires, 2002, p. 473. Sobre distintos supuestos de competencia en razón de la materia, véase GILS CARBÓ, ALEJANDRA M., *Régimen Legal de las Bases de Datos y Habeas Data*, Buenos Aires, 2001, ps. 272 y sigtes.

recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Martínez" (19).

Ahora en lo que respecta al cuerpo legal citado sobresale la regulación propia y específica del instituto, como ser: la legitimación activa, el marco competencial y el procedimiento a seguir. Por el otro el precedente señalado indica la innecesariedad de que concurra la "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta", que menta la normativa del amparo clásico (art. 43, primer párrafo, de la Constitución Nacional), en el actuar o en la omisión en el tratamiento de los datos, lo cual reforzaría su carácter autónomo.

Por todo ello creemos que la reforma constitucional de 1994 ha abierto un abanico muy interesante no sólo de derechos sino de garantías, con nuevos bríos y dimensiones, suministrando un arsenal de derechos y acciones para cubrir diversas hipótesis como en el caso de la autodeterminación informativa. Es que el derecho sin garantía es letra muerta, es un vano intento del legislador (constitucional u ordinario) de regular la realidad que desborda y entorpece a la convivencia ordenada.

(19) CSJN, en la causa "Martínez c. Organización Veraz S.A.", fallo ya citado.

CAPITULO II

EL HABEAS CORPUS. SU EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL Y JURISPRUDENCIAL

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Evolución histórica: a) Derecho Romano. b) Derecho Español. c) Derecho anglosajón: c.1) Reino Unido, c.2) EE.UU. — 3. El habeas corpus en países latinoamericanos. a) Honduras. b) Ecuador. c) México. d) Cuba. e) Perú. f) Chile. — 4. Antecedentes en Argentina. — 5. Diferentes categorías de habeas corpus. a) Clásico o reparador. b) Preventivo. c) Correctivo. d) Restringido. e) Esclarecedor. — 6. El habeas corpus esclarecedor aun durante la vigencia del estado de sitio. — 7. Desaparición forzada de personas: protección otorgada. — 8. Habeas corpus colectivo. — 9. A modo de conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

El "habeas corpus" resulta ser la pieza clave del Estado de Derecho, ya que sin este instituto no se podría construir una sociedad basada en el respeto por la ley y las libertades individuales físicas ambulatorias.

Es una garantía absoluta frente a cualquier intento de autoritarismo por parte del Estado, que protege a las personas con motivo de una posible o efectiva detención sin orden escrita de autoridad competente, basada en ley anterior al hecho.

No debemos olvidar que a raíz de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, el habeas corpus quedó incorporado a la Carta Magna bajo el art. 43, agregando a este instituto la posibilidad de ser aplicado también en el caso de la "desaparición forzada de personas"; ésta no es una consideración más sino es una extensión muy relevante, que hace modificar la clasificación clásica de los tipos de habeas corpus existentes, en una nueva con condimentación de nuestra historia política de épocas pasadas y de la lucha contra los abusos del poder, siendo por ello conveniente, tanto su examen pormenorizado como el análisis de su estado actual.

Finalmente, pero esta vez por medio de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, observamos la creación del habeas corpus colectivo, no ya por cuestiones de una sola persona sino de un grupo signifi-

cativo de individuos que ven alteradas las formas y las condiciones de sus detenciones.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Veamos cómo este instituto evolucionó en los distintos regímenes normativos a través de la historia.

a) Derecho romano

El antecedente más remoto del "habeas corpus" parece ser el interdicto romano denominado "*homine libero exhibendo*" (1).

Este implicaba una especie de acción popular que sólo podía ser ejercida por los hombres libres, ya que el esclavo no estaba protegido como así tampoco el "*redemptus*" situado en una escala intermedia entre el ser libre y el esclavo.

Se basaba en la exhibición del cuerpo del sujeto para determinar su estado físico y los motivos de su detención. Fue creado por el Pretor a fin de completar la ley "*Fabia de plagiaris*". Esta ley establecía una pena de cincuenta mil sextercios al que hubiera secuestrado, vendido o comprado a un ciudadano romano y permitía ocurrir ante el Pretor para requerir la fuerza pública a fin de liberar al detenido.

Interesa subrayar que este interdicto romano no procedía si el detenido estaba allí por su propia voluntad. Sin embargo, si el presunto consentimiento obedecía a engaño y existía dolo, procedía tal instituto.

Aparte del interdicto "*homine libero exhibendo*", existían los siguientes:

- a) "*Interdictum de liberis exhibendis et ducendis*": otorgado al pater familiae para lograr la devolución de alguno de sus descendientes al hogar.
- b) "*Interdictum de uxore ducenda vel exhibenda*": otorgado al marido respecto de su esposa en caso de que haya hecho abandono del hogar. Se obligaba a que sea exhibida para convencerla de retornar a su hogar familiar.
- c) "*Interdictum de liberto exhibendo*": concedido al patrono para lograr que el esclavo le realizare determinados trabajos en su vivienda (2).

(1) Se discute, sin embargo, el valor del "interdicto homine libero exhibendo" como antecedente del habeas corpus. Ver CARNELLI, LORENZO: "El habeas corpus. Concepto, Especies. Características propias y diferenciales. Definiciones", LA LEY, III-235, julio-septiembre de 1936, Sección Doctrina.

(2) SAGÜES, NESTOR, *Habeas Corpus*, Buenos Aires, 1988, Capítulo Primero.

b) Derecho español

En el derecho foral español, particularmente en el Reino de Aragón (siglos XIII al XVIII) existía un procedimiento muy similar al recién estudiado que se denominaba "juicio de manifestación", el cual se dividía en:

- "Juicio de manifestación de personas privadas":

El fin buscado era que se exhiba al juez al particular retenido por otra persona de carácter privada. El magistrado contaba con facultades para extraer al detenido de la casa donde se encontrara. Esta acción fue sumamente utilizada en el derecho privado, en el caso que los padres se negaran al casamiento ya acordado de sus hijos.

- "Juicio de manifestación de jueces":

Protegía a los habitantes del lugar que se encontraran presos sin procesos o por un juez incompetente. También se utilizaba para aquellos individuos a los cuales se los torturaba. Si la persona obtenía un fallo a su favor en este tipo de juicio, podía llegar a ser liberado ya sea bajo fianza o caución juratoria. También podía lograr la detención domiciliaria o ser trasladado a la "Cárcel de los Manifestados" donde el reo esperaba la sentencia de su proceso. Esta cárcel tenía a su favor el hecho que cualquier ciudadano podía comprobar el estado de salud del detenido.

- "Juicio de manifestación por vía privilegiada":

Consistía en un juicio sumárisimo en el cual el juez debía decidir la cuestión inmediatamente después que le fuera presentada. Por ejemplo se otorgaba en favor de aquellos que llevaban más de setenta y dos horas detenidos sin mediar una demanda judicial o querrela (3).

c) Derecho anglosajón

c.1) Reino Unido

La protección y defensa de la libertad tanto física como ambulatoria, dentro del derecho anglosajón, se instrumentó por medio de diversos trámites procesales que se conocen con el nombre de "*writs*" que significa un mandato judicial.

Existían diversas clases de "*habeas corpus*" de acuerdo al fin a utilizarse. A saber: remitir a una persona de un lugar de detención a otro (*ad respondendum*); trasladarla a otra jurisdicción judicial para iniciarle allí el proceso (*ad prosequendum*); traerla para que declare en el proceso (*ad testificandum*); traerla para que el proceso continúe en un juicio por deudas (*ad causa*).

Pero el habeas corpus por excelencia era el "*writs of habeas corpus ad subjiciendum*" el cual obligaba al guardián o custodio de un detenido a exhi-

(3) *Ibidem*, op. cit.

su libertad.

El writ de "habeas corpus", nace de las facultades del monarca de controlar cualquier actividad jurisdiccional del reino. De allí que en sus comienzos emerge para sustraer a un inculcado de un proceso ante un tribunal inferior para llevarlo ante otro superior (el del príncipe). Luego, se transforma en una garantía individual para tutelar la libertad física. Fue recepcionada por la Carta Magna de 1215 de la siguiente manera: "...ningún hombre libre será prendido o encarcelado o desposeído de sus bienes o proscripto o desterrado o de cualquier otro modo castigado, ni iremos nosotros sobre él ni mandaremos contra él, sino previo el juicio legal de sus pares o en virtud de la ley del país" (4).

Dado que el "habeas corpus" carecía de adecuada sanción para el caso de desatención o incumplimiento, su operatividad dejaba mucho que desear. Otro inconveniente era que se encontraba reservado a determinados tribunales y funcionarios políticos para que se pudiera emitir el auto.

En mayo de 1679 se sancionó el "Habeas Corpus Act", que si bien no implicó un aumento de los derechos de los individuos, sirvió para instrumentarlos de una manera más adecuada. Esta ley obligaba a los sheriffs y carceleros a presentar al detenido dentro de los tres días en caso de ser requerido, y en caso de incumplir se fijaban multas pecuniarias de importancia.

En el año 1816 se sancionó una nueva "Act" que aseguró el "habeas corpus" para garantizar la libertad de una persona privada de su libertad por funcionarios estatales o por simples particulares. La "Administration of Justice Act" de 1960 completa el panorama en el aspecto de las apelaciones correspondientes.

c.2) Estados Unidos de América

En la constitución de 1787 se incorporó explícitamente el "habeas corpus" heredado del Reino Unido de 1679 y en general de la tradición jurídica anglo-norteamericana.

Este instituto en los Estados Unidos de América es visto principalmente como un procedimiento en el que se defiende el derecho a la libertad y requiere como presupuesto indispensable que exista un detenido bajo determinadas condiciones de alojamiento.

La corte ante la cual se interpone debe averiguar la causa de la detención (5) y la jurisdicción del tribunal bajo el cual se encuentra apresado. También este instituto ha sido empleado con el fin de ordenar la excarcelación bajo fianza cuando la misma fuera procedente y hubiese sido negada por el juzgado de primera instancia a cuya disposición se encontrara el reo. Sostuvo la Corte Su-

(4) JAGERSKIOLD, STIG, *The Freedom of movement*, en Henkin, Loris (ed.) "The International Bill of Rights", New York, 1981, ps. 166/170.

(5) Ver, p.ej., CARNOTA, WALTER F., "¿Habeas corpus para los detenidos en Guantánamo?", en www.eldial.com, diciembre de 2003.

prema que un segundo juicio y castigo por el mismo crimen es un exceso de autoridad judicial ante el cual es factible el habeas corpus para procurar la libertad.

Otra variante singular de la utilización del "habeas corpus" ha sido su aplicación para obtener o recuperar la custodia de niños y para determinar el derecho de las partes (padre, madre u otro pariente) para ejercer dicha custodia.

3. EL HABEAS CORPUS EN PAÍSES LATINOAMERICANOS (6)

a) Honduras

En la constitución de 1957 se admitió la garantía del "habeas corpus" siendo ineludible la exhibición del detenido en cuyo favor se hubiera presentado el recurso. No sólo amparaba al ilegalmente privado de su libertad sino también al que sufre vejámenes aun cuando su prisión fuese fundada en ley. El objeto de la acción era cesar la restricción ilegal.

b) Ecuador

Dispone que toda persona que creyera estar ilegalmente privada de su libertad, podrá acogerse a este beneficio, pudiendo ejercerlo personalmente o por terceros. La autoridad judicial ordenará que el individuo sea conducido a su persona. A su vez, la misma norma establece que el funcionario que no acatare la orden será destituido de su cargo sin más trámite.

c) México

Se admite contra decisiones judiciales y también contra actos de otros órganos.

El texto constitucional es uno de los clásicos en esta materia. Allí se declara que los tribunales resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que viole garantías individuales. A su vez, se instituye el trámite del amparo el cual se limitará en su diligenciamiento "al informe de la autoridad, a una audiencia para la cual se citará en el mismo auto en que se manda pedir el informe y que se verificará con la mayor brevedad posible, recibiendo-se en ella las pruebas que las partes interesadas ofrecieren y oyéndose los alegatos que no podrán exceder de una hora cada uno y a la sentencia que se pronunciará en la misma audiencia".

d) Cuba

El proceso tiene carácter sumarísimo y se articula ante los tribunales ordinarios y a sea por el mismo detenido o por terceros sin necesidad de contar con patrocinio letrado.

(6) LÓPEZ GUERRA, LUIS y AGUIAR DE LUQUE, LUIS (editores), *Las Constituciones de Iberoamérica*, Madrid, España, 1992.

Su constitución indica que el Tribunal no podrá declinar su jurisdicción ni admitir cuestiones de competencia en ningún caso ni por motivo alguno, ni aplazar su resolución que será preferente a cualquier otro asunto. La presentación del detenido es obligatoria a los efectos de verificar los motivos de su privación y el agravamiento de las condiciones de detención. En el caso de no concretarse tal exhibición, se dispondrá el arresto del infractor. Cualquier dilación en el trámite será nula y los magistrados que se negaren a admitir la solicitud del mandamiento del habeas corpus o no cumplieran con las disposiciones establecidas serán separados de sus cargos.

e) Perú

En la ley del 21 de octubre de 1897 (7) se adoptó este instituto. A su vez, al sancionarse la Constitución en el año 1979 se estableció que "la acción u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnerase o amenace la libertad individual de un ciudadano, dará lugar a la interposición de esta acción".

Asimismo, este instituto se utiliza ante amenazas a la libertad personal, sea que provenga de actos u omisiones de autoridades, funcionarios o particulares y con el objeto que dichas intimidaciones cesen o no lleguen a concretarse.

f) Chile

Se instituyó el amparo a la libertad física al establecerse que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso por infracción al acta constitucional o a las leyes, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta ordene que se guarden las formalidades legales y adopten de inmediato las providencias que juzgue necesarias para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

La misma norma señala que la magistratura aludida podrá ordenar que la persona detenida sea traída a su presencia y tal decreto deberá ser precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o centros de detención. La norma dispone: "Instruida de los antecedentes la Corte decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo en forma breve y sumariamente". Cualquier otro tipo de privación, perturbación o amenaza ilegal a la libertad personal y seguridad individual, da lugar a un recurso análogo al expuesto.

4. ANTECEDENTES EN LA ARGENTINA

En lo que en nuestro país respecta, y como primer antecedente del "habeas corpus", aparece en el reglamento de la Junta Conservadora del 22 de

(7) Ver GARCIA BELAUNDE, DOMINGO, *El Habeas Corpus en el Perú*, Lima, 1979, Capítulo II.

octubre de 1811. El decreto sobre seguridad individual del 23 de noviembre de 1811 es el primer antecedente nacional que hace referencia a la validez de la detención sujeta a una orden escrita. Además aparece en el proyecto de la constitución federal para las Provincias Unidas de América del Sur de 1813 como así también en el Estatuto provisional del 15 de mayo de 1815.

En el proyecto de constitución del congresista De Angelis, se establecía que nadie podría ser arrestado sino en los casos señalados expresamente por la ley, castigándose severamente al que ordene o ejecute una prisión arbitraria. Finalmente, la Constitución Nacional del año 1853 no regula este instituto en forma expresa, sino que se lo considera incorporado tácitamente. En efecto, entre los sostenedores de esta corriente se encuentran Quiroga Lavie y Bielsa quienes afirman que "el habeas corpus" se encuentra incluido en nuestra constitución "en sus declaraciones y principios básicos", desprendiéndose de su art. 18 puesto que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente.

Luego de sancionada la Constitución de 1853, la primera reglamentación de esta garantía fue el art. 20 de la ley 48. Sancionada el 25/08/1863 y promulgada el 14/09/1863, que fuere derogado con posterioridad por el art. 28 de la ley 23.098 —conocida como ley de habeas corpus— (8).

Pero recién en la reforma del año 1949 se la incluyó en forma expresa como garantía constitucional. Allí se determinó que todo habitante podrá interponer por sí o por intermedio de sus parientes o amigos, recurso de habeas corpus ante la autoridad judicial competente para que se investiguen la causa y el procedimiento de cualquier restricción o amenaza a la libertad de la persona. El Tribunal hará comparecer al recurrente en forma inmediata y comprobará en forma sumaria si existen tales violaciones y en su caso hará cesar de inmediato su restricción o amenaza.

Con la reforma constitucional de 1994, la mención de habeas corpus quedó estipulada en el art. 43 el cual establece en su cuarto párrafo que "....cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio..."

Asimismo, el procedimiento a utilizarse por los Tribunales se encuentra prescripto en la citada ley 23.098 promulgada el 19 de octubre de 1984, siempre que su texto no altere o contradiga el citado art. 43. Básicamente se procura con esta ley la protección de los derechos de los individuos contra actos de autoridad pública que impliquen:

(8) Ver SABSAY, DANIEL y ONAINDIA, JOSE M., *La Constitución de los argentinos —análisis y comentario de su texto luego de la reforma de 1994—*, Buenos Aires, 1995, p. 153.

209

amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente.

- Agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere.

5. DIFERENTES CATEGORÍAS DE HABEAS CORPUS

Del texto de la nueva normativa constitucional y siguiendo a la ley 23.098 se pueden desprender las siguientes categorías de habeas corpus:

- Habeas corpus clásico o reparador:** Este se interpone para hacer cesar la restricción o privación ilegal de libertad física y ambulatoria por parte de la autoridad pública o de particulares.
- Habeas corpus preventivo:** Se dirige a evitar la privación ilegal de la libertad física y ambulatoria en sentido amplio, ante la amenaza ciertas o inminente de detención arbitraria.
- Habeas corpus correctivo:** En este caso su finalidad apuntará a terminar con actos u omisiones que agraven indebidamente la situación de una persona detenida legalmente.
- Habeas corpus restringido:** Que tiende a hacer cesar limitaciones, atentados o molestias ilegítimas que perturban la libertad de locomoción o ambulatoria, sin llegar a la detención o privación de la libertad.
- Habeas corpus esclarecedor:** Si bien esta categoría no se encuentra descripta en los diferentes tipos de habeas corpus detallados precedentemente por la doctrina, encontramos necesaria su inclusión como una nueva categoría, sobre la base de los argumentos que vertimos a continuación.

6. EL HABEAS CORPUS "ESCLARECEDOR" AÚN DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE SITIO (9)

Como podrá visualizarse si confrontamos el nuevo texto de la Constitución Nacional del año 1994, no encontramos ningún tipo de innovaciones en lo que a su clasificación tradicional respecta, pero sí los convencionales constituyentes tuvieron la feliz convicción de dejar estipulado una novedosa categoría de habeas corpus y nada menos que en el texto constitucional, que ya que se venía utilizando mediante diferentes presentaciones en los tribunales

(9) Ver MARANIELLO, PATRICIO ALEJANDRO y ROZAS, JUAN, "El Habeas Corpus esclarecedor en la desaparición forzada de personas", LA LEY, DJ, Bs. As. 2002.

de justicia durante los gobiernos de facto, aunque en la mayoría de los casos fueron rechazados.

Esta forma o clase de habeas corpus es la que denominamos "esclarecedor"; la utilización de este término obedece principalmente a que la nueva norma tiende a tratar de establecer o esclarecer el destino actual de la persona que se encuentra privada de su libertad, pero no como en el caso del habeas corpus clásico o reparador en que aquella se encuentra detenida en forma ilegítima en una dependencia del estado. En el nuevo instituto, lo que no se conoce es el órgano que lo ha detenido o bajo qué condiciones; lo que sí se tiene conocimiento, es que existió una autoridad pública en uso de la fuerza la ha privado de su libertad física ambulatoria sin ningún tipo de constancia a tales efectos.

Este tipo de habeas corpus no puede utilizarse cuando la desaparición forzada provenga de un particular, por que estaríamos —en este caso— frente a las figuras penales tipificadas en los arts. 140 al 149 y 170 del Código Penal de la Nación.

Volviendo al término "esclarecedor", podemos decir que con ello queremos brindarle a esta figura jurídica un fin específico; frente a una privación de la libertad física que trajo como resultado la desaparición de la persona ejercida en forma coactiva que se presume llevada a cabo por algún organismo estatal, la autoridad judicial competente deberá esclarecer, lo siguiente: a) en primer término, el paradero de la persona, b) luego en caso de una respuesta negativa a dicho pedido los diferentes organismos del Estado deberán volcar toda información que conste en sus archivos sobre dicha persona y especialmente sobre sus últimas tareas de que se tengan constancias, y c) finalmente, el juez deberá requerir a los organismos de seguridad de la Nación la dilucidación de dicha situación.

Por último, el art. 43 en su parte "in fine" establece que ningún tipo de habeas corpus puede ser restringido durante la vigencia de un estado de sitio decretado por el Estado. Ello no significa que esta garantía constitucional tiende a suspender o alterar la figura del estado de sitio, sino que a los jueces les incumbe revisar la razonabilidad en la adecuación de causa y grado entre las restricciones impuestas y los motivos determinantes en la declaración del estado de sitio. Dicho control es un deber del Poder Judicial, en especial de la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de garantías constitucionales, pero es impuesto en interés del buen orden de la comunidad y del propio órgano político (10).

7. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS: PROTECCIÓN OTORGADA

Por la ley 23.054 la República Argentina aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dotándola con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994.

(10) CSJN, Fallos: 298: 441; 300:816; 303:397, entre otros.

Al reconocerse la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —organismo creado por la convención—, las violaciones a los derechos allí protegidos que no encuentren respuesta en el ámbito interno, pueden llegar a trascender a dicha jurisdicción internacional.

Debe tenerse presente que además la Corte Interamericana considera que intentado el "habeas corpus" sin resultado positivo, y en el caso que la persona a cuyo favor se presentó no aparece, se tiene por cumplido el requisito del agotamiento de los recursos internos como condición previa para acceder a la instancia internacional, conforme lo establecido por el art. 46 inc. 1 del Pacto de San José de Costa Rica, podrá presentarse ante los organismos jurisdiccionales interamericanos.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas consideró que "a los efectos de la presente convención, se considera desaparición forzada de personas la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes" (11).

Cabe destacar la importancia que reviste esta Convención al adquirir jerarquía constitucional en virtud de la ley 24.820 —B.O. 29/05/97—.

Asimismo, la Corte Interamericana, al resolver un caso planteado, podrá llegar a disponer que se garantice al lesionado el pleno goce de sus derechos y libertades. Dispondrá, si fuere precedente, que se reparen las consecuencias de la medida ejecutada en su perjuicio y el pago de una indemnización.

El fallo emitido es definitivo e inapelable (12); sin embargo, en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del veredicto, se admite un recurso de interpretación, siempre que se haya presentado dentro de los noventa días de la fecha de notificación.

Es conveniente remarcar que para que un Estado pueda ser demandado o demandante, debe haberse efectuado una declaración de reconocimiento de la competencia por la Corte Interamericana la cual podrá ser formulada por una manifestación formal o ante la Secretaría General de la O.E.A.

Ahora bien, en nuestro país a partir de la sanción de la ley 24.321 se incorpora al marco jurídico argentino "la ausencia por desaparición forzada", que se podrá declarar por toda aquella persona que hasta el día 10 de diciembre

(11) Art. 2º de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Aprobada por ley 24.556 —B.O. 18/10/1995—.

(12) A mayor abundamiento consultar, LAVIÑA, FELIX, *Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos*, Buenos Aires, 1987.

de 1983 hubiera desaparecido involuntariamente de su domicilio o residencia y sin que se tenga noticia de su paradero.

Se determinó que a los efectos de esta ley se entendía por desaparición forzada de personas cuando se hubiere privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima o si ésta hubiera sido alojada en lugares clandestinos de detención, o privada bajo cualquier otra forma del derecho a la jurisdicción.

Recibida que fuera la solicitud de ausencia por desaparición forzada o involuntaria, el juez requerirá al organismo oficial ante el cual se formuló la denuncia de la desaparición, o en su defecto, el magistrado donde se presentó el habeas corpus, información sobre la veracidad formal del acto y ordenará la publicación de edictos. Transcurridos sesenta días desde la última publicación y previa vista al defensor de ausentes, se procederá a declarar la ausencia por desaparición forzada, fijándose como fecha presuntiva de la misma el día que constaba en la denuncia originaria.

De tal forma, se dio cobertura a todos aquellos ciudadanos que de algún modo hayan sufrido la persecución del Estado, sin saber en algunos casos su actual paradero.

8. HABEAS CORPUS COLECTIVO (13)

Como clonación de la disposición contenida en el segundo párrafo del art. 43 CN (amparo colectivo), y sobre la base del instituto regulado por el cuarto párrafo de ese mismo artículo ("habeas corpus correctivo"), la mayoría de la Corte Suprema de Justicia dio vida a una nueva figura: el "habeas corpus colectivo". En esta extensa decisión, en donde un bloque compacto de jueces propicia esta solución, el Tribunal ha bajado el umbral de la inspección de constitucionalidad (aunque sin declarar la invalidez constitucional de las normas, o hablar de la "inconstitucionalidad por omisión"), admitiendo una modalidad intensa de contralor que se venía insinuando pero que nunca antes se había explicitado con todas las letras (14).

Desde el año 2004 (v. "Banco Comercial Finanzas", sentencia del 19 de agosto de 2004 (Fallos: 327:3117), la Corte ha proseguido con un ejercicio pro-activo de la "judicial review", ya insinuada en otro precedente carcelario, "Mignone", del año 2002 (Fallos: 325:524). El 29 de marzo de 2005, en la causa "Itzcovich", la Corte celosamente defendió su rol de Tribunal cimero al expeler de su radio de conocimiento pleitos previsionales ordinarios que poco tenían que ver con su augusta función, lo cual fue prontamente receptado por el legislador en la ley 26.025 que finalmente derogó el cuestionado y cuestionable art. 19 de la ley 24.463.

(13) Ver CARNOTA, WALTER F., "Un problemático supuesto de 'habeas corpus colectivo' (Nota al fallo "Verbitsky"), *eldial.com* del 6/5/2005.

(14) CARNOTA, WALTER, *ibídem*.

206

continúa llamamos requisito de la afectación concreta, del daño específico e individualizado ("injury"), y la proyecta en el campo del control abstracto de constitucionalidad. No sólo la Corte se embarca en un "diálogo de poderes"; aquí directamente frente al colectivo de prisioneros, le señala a los tres poderes constituidos de la Provincia de Buenos Aires lo que tiene puntualmente que hacer. No hay sugerencias ni "poderes implícitos": hay fijación de políticas de Estado.

Desde siempre hemos aplaudido a los llamados "procesos grupales". Hemos abogado por la importación de las "class actions" en ciertas materias. Aplaudimos la legitimación activa del Defensor del Pueblo de la Nación en los términos del art. 43 segundo párr. citado y del art. 86, ambos del plexo base.

No se nos escapa tampoco —y el fallo es muy contundente en esto— las deplorables situaciones de las cárceles provinciales, con superpoblación, hacinamiento y todo lo que ello trae aparejado para los reclusos y para terceros. Pero sinceramente nos cuesta detectar en claridad si, más allá del "nomen iuris" que como bien puntualiza la Corte es contingente (la acción podría haberse encaminado como un amparo colectivo por discriminación, y se terminaba la discusión) y al margen del original aunque no literal argumento "por lo mayor" del consid. 16, nos hallamos frente a un "derecho de incidencia colectiva". Ahí está el núcleo del problema a examinar en esta ocasión.

Para que se presente esta hipótesis, creemos que debe haber una afectación homogénea a un colectivo de personas. Y por más patentes y elocuentes que son las palabras de la Corte sobre las penurias a los que se ven sometidos muchos presos en las prisiones bonaerenses, no se viola en todos los casos los derechos a la integridad psicofísica, a la salud y por qué no a la vida, cuyas ilegítimas vulneraciones deben resolver los magistrados de cada jurisdicción. De este enunciado, hacemos excepción —dentro de una indagación más "clínica"— respecto de lo afirmado en torno al alojamiento de adolescentes y enfermos en comisarias, en donde si se reúnen a nuestro criterio los recaudos apuntados de incidencia grupal.

Reivindicamos aquí la singularidad de cada detención, o al menos de cada comisaría o de cada presidio, con sus matices que deben ser computados a la hora de corregirlos. No se puede hacer una generalización que, fundada en la mejor de las intenciones, alimenta al fantasma del "legislador negativo" del que hablara otrora Hans Kelsen.

¿Cómo enseñaremos ahora que la Corte no emite "advisory opinions"? ¿Es ésta una opinión consultiva, o una "sentencia de necesidad y urgencia"? ¿Por qué legitimamos a las organizaciones no gubernamentales, y no al Defensor del Pueblo a quien sistemáticamente se ha negado su "day in court"? ¿Tiene sentido venir ahora a hablar de la caducidad de 15 días en el amparo? Jurisdicciones inferiores "beware": se acabaron subterfugios microprocesales. Ahora hay que ver siempre el "gran cuadro", el "bosque" y no "el árbol".

deralismo. La política carcelaria en concreto es hija de pautas procesales que por la "cláusula residual" (sic) del art. 75 inc. 12 es "provincial".

Es verdad que el federalismo argentino, como enfatiza la Corte, no es igual que el norteamericano. Sin embargo, la "reforma" de 1860 procuró acercarlos.

El fallo pone en virtual antagonismo a las autonomías locales y a directivas internacionales que como las recogidas en la ley 24.660 son federales pero no "gozan de jerarquía constitucional" en los términos del art. 75 inc. 22. Los documentos de derechos fundamentales que sí tienen ese rango suministran reglas de textura bastante abiertas como para aplicar sin más a todas las cárceles de la Provincia más difícil del país. Las peculiaridades locales no se pueden alzar bajo ningún punto de vista por encima de los derechos contenidos en el bloque constitucional, o en una ley federal (arg. art. 31), pero hay que dar un margen institucional a la autoridad local, al igual que la "apreciación nacional" de que hablan los organismos internacionales, para determinar las violaciones a la preceptiva máxima.

Hay una muy fina línea que se torna borrosa entre la evaluación de la "oportunidad, el mérito o la conveniencia de las medidas adoptadas por la administración provincial, ni poner en discusión su política penitenciaria, y menos aún, su política criminal en la parte que le compete" (consid. 25), y lo aquí resuelto.

Es que el Alto Tribunal ha actuado como "una Corte Constitucional" que "fija pautas y establece estándares jurídicos a partir de los cuales se elabora la política en cuestión" (consid. 26). El "self-restraint" que mostraron las jurisdicciones superiores provinciales ha dado paso a un activismo que se da en un contexto, justo es reconocerlo, de desertión de los poderes políticos frente a un problema humano y jurídico de envergadura

9. A MODO DE CONCLUSIÓN

Podemos notar que gracias a esta acción, se protegió desde tiempos remotos uno de los mayores derechos individuales de la persona que es la libertad tanto física como ambulatoria, denotando una perfección a lo largo del tiempo en su uso, llegando en algunos países como en Estados Unidos de Norteamérica a usarse como vía recursiva ante la negativa al pedido de la excarcelación bajo fianza.

En nuestro país, con la reforma constitucional del año 1994, se obtuvo en su art. 43 la regulación expresa, luego de tantos años de su uso por vía legislativa, adquiriendo rango constitucional expreso, con sus nuevas connotaciones en el caso de desaparición forzada de personas con características a nuestro entender propias, con la incorporación de una nueva categoría de habeas corpus al que denominamos "esclarecedor".

207

dicta un nabeas corpus colectivo fijando pautas para mejorar la situación carcelaria, ante la desidia de los Poderes Políticos.

Por todo ello, consideramos que este nuevo instituto sirve para fortalecer la idea de República democrática que inspiró el dictado de nuestra Carta Magna, uno de cuyos máximos valores es la libertad, ya que ésta es esencial en todos los órdenes de la vida, recordando lo dicho por Víctor Hugo "... la libertad es, en la filosofía, la razón; en el arte, la inspiración; en la política, el derecho...".

CAPITULO III.1

LOS RECURSOS EXTRAORDINARIO Y ORDINARIO ANTE LA CORTE SUPREMA

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Función del Recurso Extraordinario. — 3. Requisitos formales del R.E. — 4. Requisitos del control. — 5. Comparación con el sistema federal de EE.UU. a) Proyectos de la convención constituyente de Filadelfia. b) Competencia Federal y Estadual. b.1) Aplicación de normas federales y estaduais. b.2) Conflicto entre distintas jurisdicciones y distintas leyes estaduais. b.3) Plena fe de las decisiones de los estados. c) Comparación en el control de constitucionalidad. — 6. Requisitos formales y efectos. a) Forma, plazo y trámite. b) Llamamientos de autos. c) Certiorari. d) Memorial. e) Efectos. — 7. Recurso ordinario. a) Requisitos. b) Forma y plazo. c) Llamamiento de autos. d) Posturas de la CSJN. d.1) Circunstancias en que proceden. d.2) Circunstancias en que no proceden. — 8. Recurso de queja. — 9. Requisitos formales de la Acordada 4/07. — 10. Audiencia pública. — 11. Conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

El art. 116 de la Constitución Nacional, en concordancia con lo dicho por Hans Kelsen, establece que el Poder Judicial es el único guardián de la Constitución, pero lo hace en forma difusa y a través de la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación y no como un tribunal concentrado como era la creencia del jurista citado.

Si bien la Corte realiza un control de constitucionalidad en toda intervención que efectúa, sea ésta a través de un recurso ordinario de apelación, por vía originaria y exclusiva, recurso de queja, recurso de revisión, la propia Corte dice que a través del Recurso Extraordinario (en adelante "R.E.") es donde se realiza su potestad máxima. El R.E. es el móvil más frecuente para llegar a la Corte Suprema.

¿Pero cuáles son los parámetros, límites y extensión del control de constitucionalidad a través del Recurso Extraordinario? Uno de los problemas que más gravemente afectan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la excesiva carga de trabajo (1).

(1) www.elnotarioargentino.com.ar/archivo_normas/proy_causascorte.